

Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT

Nummer 7130/216

Betreft zaak: Taxivervoer IJsselsteden

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
1.1	Verloop van de procedure.....	3
1.2	Betrokken ondernemingen	5
1.3	Het Rapport.....	6
1.4	Opbouw van dit besluit.....	7
2	PROCEDURELE ASPECTEN	7
3	CONTRACTUEEL TAXIVVERVOER	8
3.1.	Vormen van contractueel taxivervoer	8
3.2.	Wijze van verkrijgen van opdrachten.....	10
3.3	Aanbieders van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam	11
4	FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN TEN AANZIEN VAN DE GEDRAGINGEN	12
4.1	De aanloop naar de totstandkoming van de overeenkomst.....	12
4.2	De overeenkomst	14
4.3	Vervolg op de totstandkoming van de Overeenkomst	17
4.4	Zienswijze m.b.t. de feiten en omstandigheden en de beoordeling door de Raad	25
4.5	Einde van de samenwerking	26
4.6	Conclusie ten aanzien van de feiten en omstandigheden	27
5	JURIDISCHE BEOORDELING	28
5.1	Artikel 6 Mw	28
5.2	Overeenkomst	29
5.3	Mededingingsbeperking	30
5.4	Merkbaarheid	39
5.5	Bagatelbepaling.....	44
5.6	Artikel 6, derde lid, Mw	45

5.7	Duur van de overtreding	46
5.8	Eindconclusie met betrekking tot artikel 6 Mw	46
6	ONDERNEMING EN TOEREKENING	47
7	SANCTIE	50
7.1.	Faillissement IJsselsteden.....	50
7.2.	Boetegrondslag	51
7.3.	De ernst van de overtreding	52
7.4.	Boeteverhogende en –verlagende omstandigheden.....	54
7.5.	Wettelijk maximum	57
7.6.	Conclusie sanctie	57
8	BESLUIT.....	58

1 INLEIDING

1.1 Verloop van de procedure

1. De Directie Mededinging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) heeft op 6 januari 2009 een onderzoek ingesteld naar een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) door ondernemingen die actief zijn op het gebied van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam.
2. Het onderzoek betrof onder meer de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. (hierna: RMC) en IJsselsteden Beheers Groep B.V. en haar dochteronderneming IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. (hierna tezamen: IJsselsteden). RMC en IJsselsteden worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als “de betrokken ondernemingen”.
3. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw door het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie, dan wel het afstemmen van inschrijfgedrag voorafgaande aan de inschrijving op aanbestedingen van contractueel taxivervoer, in het bijzonder de aanbesteding Collectief Aanvullend Vervoer in Rotterdam. In dat kader zijn op 19 mei 2010 bedrijfsbezoeken uitgevoerd bij onder andere RMC. Naar aanleiding daarvan is het onderzoek uitgebreid met een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw door het aangaan van overeenkomsten die tot doel hebben de markt te verdelen ten aanzien van aanbestedingen van contractueel taxivervoer, in het bijzonder in Zuid-Holland.
4. In dat kader heeft de NMa vervolgens op 31 augustus 2010 bij IJsselsteden een bedrijfsbezoek uitgevoerd. Bij de bedrijfsbezoeken aan RMC en IJsselsteden is inzage gevorderd in schriftelijke gegevens en bescheiden en zijn hiervan kopieën gemaakt. Verder zijn op verschillende locaties forensische images c.q. digitale kopieën van digitale omgevingen gemaakt. Daarnaast heeft de NMa verklaringen afgenomen van (voormalig) directeuren, commissarissen en medewerkers van RMC en IJsselsteden.
5. Na het onderzoek van de Directie Mededinging is het redelijk vermoeden gerezen dat RMC en IJsselsteden in de periode 17 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 hebben deelgenomen aan een overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging die ertoe strekte de mededinging te beperken dan wel te vervalsen door afspraken te maken die voorzien in marktverdeling, bestaande uit een verdeling van opdrachten op het gebied van

contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam.¹

6. Uit het onderzoek is voorts het vermoeden gerezen dat de heer [vertrouwelijk] (hierna: de heer [A]), [leidinggevende] van de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V., de heer [vertrouwelijk](hierna: de heer [B]), [leidinggevende] van de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V., de heer [vertrouwelijk] (hierna: de heer [C]), voormalig [leidinggevende] van IJsselsteden Beheers Groep B.V. en de heer [vertrouwelijk] (hierna: de heer [D]), voormalig [redacted] van IJsselsteden Beheers Groep B.V., in de periode 17 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 feitelijk leiding hebben gegeven aan de gedragingen zoals genoemd in het vorige randnummer. De heren [A], [B], [C] en [D] worden hierna tezamen aangeduid met “feitelijk leidinggevers”.²
7. Het onderhavige besluit richt zich tot RMC en IJsselsteden; de feitelijk leidinggevers ontvangen ieder afzonderlijke besluiten.
8. Met het oog op het eventueel opleggen van een boete aan de ondernemingen en feitelijk leidinggevers genoemd in de twee vorige randnummers, is in opdracht van de Raad van Bestuur van de NMa (hierna: de Raad) op 28 april 2011 een Rapport opgemaakt (hierna: het Rapport).³
9. Het Rapport is op 28 april 2011 toegezonden aan de betrokken ondernemingen alsmede aan de heer [A], de heer [B], de heer [C] en de heer [D].
10. De behandeling van deze zaak is na het opmaken van het Rapport door de Directie Mededinging overgedragen aan de Juridische Dienst van de NMa.
11. Op 23 mei 2011 zijn de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd ten kantore van de NMa en aan de betrokken ondernemingen en feitelijk leidinggevers toegezonden. De Raad heeft de betrokken ondernemingen en feitelijk leidinggevers opgeroepen schriftelijk of mondeling hun zienswijze omtrent het Rapport naar voren te brengen.⁴ IJsselsteden heeft mondeling aangegeven geen gebruik te maken van de

¹ Onder de regio Rotterdam wordt in het Rapport verstaan: de gemeente Rotterdam en de omliggende gemeenten, zoals Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Zuidplan (waaronder Nieuwerkerk aan den IJssel), Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en Spijkenisse.

² De heren [C] en [D] waren ten tijde van de overtreding beiden [vertrouwelijk] van IJsselsteden Beheers Groep B.V. In de periode tot 4 maart 2010 via Institorium Beheer B.V. respectievelijk Ypsilon Beheer B.V. en vanaf die datum tot 27 augustus 2010 rechtstreeks.

³ Op het Rapport staat als grondslag artikel 59, eerste lid, Mw genoemd. Ingevolge ABRvS 1 juni 2011, *LJN*: BQ6826 en CBb 22 juni 2012, *LJN*: BW9146, moet dit zijn: artikel 5:48, eerste lid, Awb. Voor de rechten en plichten van de betrokken ondernemingen en natuurlijke personen maakt dit geen verschil.

⁴ In de uitnodiging werd uitgegaan van toepasselijkheid van de artikelen 60 en 61 (oud) Mw. Ingevolge ABRvS 1 juni 2011, *LJN*: BQ6826 en CBb 22 juni 2012, *LJN*: BW9146, geldt in de onderhavige zaak artikel 5:53 Awb. Voor de rechten en plichten van de betrokken ondernemingen en natuurlijke personen maakt dit geen verschil.

gelegenheid tot het indienen van mondelinge en schriftelijke zienswijzen.⁵ RMC en de feitelijk leidinggevers van RMC en IJsselsteden hebben ieder hun schriftelijke zienswijzen ingediend.

12. Op 8 september 2011 heeft RMC tijdens een daartoe georganiseerde hoorzitting mondeling haar zienswijze naar voren gebracht. Van deze hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 27 oktober 2011 aan RMC is verzonden. Zowel IJsselsteden als de feitelijk leidinggevers van IJsselsteden en RMC hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid te worden gehoord.

1.2 Betrokken ondernemingen

13. Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die statutair is gevestigd te Rotterdam. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: handelsregister) blijkt dat de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. zich onder meer bezig houdt met de exploitatie, verzorging en verdere ontwikkeling van hoogwaardige mobiliteitsdiensten in het kleinschalig vervoer.⁶ RMC richt zich op contractueel taxivervoer in de Regio Groot Rotterdam. Met Groot Rotterdam bedoelt RMC de gemeente Rotterdam en de omliggende gemeenten.⁷ Dit gebied wordt volgens RMC bepaald doordat RMC bij de uitvoering van contractueel taxivervoer gebruik maakt van taxiondernemers die zijn aangesloten bij de Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. (hierna: RTC). RTC is 49% aandeelhouder van RMC. RMC richt zich met name op zakelijk vervoer, AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. Voorts blijkt dat RMC in onderaanneming Valys-vervoer en zittend ziekenvervoer uitvoert of heeft uitgevoerd.⁸ Uit het voorgaande blijkt dat RMC alle vormen van contractueel taxivervoer kan uitvoeren.
14. IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die in de voor het onderhavige besluit relevante periode statutair was gevestigd te Capelle aan den IJssel. Uit het handelsregister blijkt dat IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. zich voornamelijk bezig hield met het verzorgen van taxivervoer. IJsselsteden richtte zich op contractueel taxivervoer in de gemeenten Capelle aan de IJssel, Zuidplas⁹, Krimpen aan de IJssel en Rotterdam. IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. was tot medio december 2007 aangesloten bij de Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. is in staat van faillissement verklaard bij rechterlijke uitspraak van 30 november 2010 en heeft haar activiteiten per die datum gestaakt.¹⁰

⁵ Bevestiging bij brief 23 mei 2011, kenmerk 7130/105.

⁶ Dossierstuk 56, met kenmerk 7130/43: memo Bedrijfsgegevens en markt, uittreksel Kamer van Koophandel van RMC.

⁷ Dossierstuk 41, met kenmerk 7130/54, volgens RMC ook wel de regio Zuid-Holland Zuid genoemd.

⁸ Dossierstuk 41, met kenmerk 7130/54: antwoorden RMC op vragen NMa, vraag 5.

⁹ Zuidplas betreft o.a. de voormalige gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht.

¹⁰ Vonnis rechtbank Breda van 30 november 2010, zaaknummer 10/659 F.

15. IJsselsteden Beheers Groep B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die in de voor het onderhavige besluit relevante periode statutair gevestigd was te Capelle aan den IJssel. IJsselsteden Beheers Groep B.V. was van 29 december 2006 tot 3 september 2010 enig aandeelhouder en bestuurder van IJsselsteden Taxi Combinatie B.V.¹¹ IJsselsteden Beheers Groep B.V. is in staat van faillissement verklaard bij rechterlijke uitspraak van 9 november 2010 en heeft haar activiteiten per die datum gestaakt.¹²
16. Op 27 augustus 2010 heeft IJsselsteden Beheers Groep B.V. voor de duur van minder dan drie weken een 100% aandeelhouder en een nieuwe directie gekregen, bestaande uit Taxi Govers B.V., gevestigd te Kaatsheuvel. Taxi Govers B.V. is met ingang van 5 oktober 2010 failliet verklaard.¹³

1.3 Het Rapport

17. Hierna worden de conclusies die het Rapport bevat ten aanzien van de feiten en omstandigheden kort samengevat, gevolgd door de juridische beoordeling uit het Rapport.

Conclusies in het Rapport ten aanzien van de feiten en omstandigheden

18. Bij randnummer 111 van het Rapport wordt geconcludeerd dat de betrokken ondernemingen (in het Rapport aangeduid met "de Deelnemende ondernemingen") "in ieder geval op 17 december 2007 mondeling een onderlinge opdrachtverdeling op het gebied van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam zijn overeengekomen (in het Rapport aangeduid met "de Afspraken"). Voorts staat vast dat de Deelnemende ondernemingen bij de Aanbestedingen LLV Capelle, buiten bestek leerlingen Capelle aan den IJssel, VOM en LLV Krimpen contact of overleg hebben gehad in het kader van de Afspraken dan wel dat er rekening is gehouden met de Afspraken. Op grond van het bovenstaande staat vast dat de Deelnemende ondernemingen met de Afspraken en de gedragingen in het kader van de Afspraken het gemeenschappelijke doel hadden de concurrentie te beperken tussen RMC en IJsselsteden bij Aanbestedingen om de continuïteit van de ondernemingen te waarborgen. Tot slot concludeert de NMa dat de Deelnemende ondernemingen de Afspraken in ieder geval tot en met 27 augustus 2010 in stand hebben gehouden."

De juridische beoordeling in het Rapport

19. Bij randnummer 137 van het Rapport wordt geconcludeerd dat "RMC en IJsselsteden in de periode van 17 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 hebben deelgenomen aan een overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging door te voorzien in

¹¹ Dossierstuk 56, met kenmerk 7130/43: memo Bedrijfsgegevens en markt, uittreksels Kamer van Koophandel van IJsselsteden.

¹² Vonnis rechtbank Breda van 9 november 2010 zaaknummer 10/616 F.

¹³ Vonnis rechtbank Breda van 5 oktober 2010 zaaknummer 10/555 F.

opdrachtverdeling op het gebied van contractueel taxivervoer in de 'regio Rotterdam'. Deze Afspraken strekten ertoe de mededinging in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw, te verhinderen, beperken of vervalsen en waren merkbaar”.¹⁴

20. Blijkens randnummers 141-143 van het Rapport zijn de rechtspersonen aan wie de overtreding wordt toegerekend de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V., IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. en IJsselsteden Beheers Groep B.V. (die van 29 december 2006 tot en met 3 september 2010 enig aandeelhouder van IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. was).

1.4 Opbouw van dit besluit

21. Hierna wordt in hoofdstuk 2 de zienswijze van RMC omtrent de procedurele aspecten weergegeven en beoordeeld. De Raad beschrijft in hoofdstuk 3 het contractueel taxivervoer, waarbij in wordt gegaan op de aanbieders van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam. In hoofdstuk 4 stelt de Raad de feiten en omstandigheden met betrekking tot de specifieke gedragingen in deze zaak vast, waarbij de Raad ingaat op de door RMC ingebrachte zienswijze, waarna de Raad zijn conclusie over de feiten geeft. Hoofdstuk 5 behandelt de juridische beoordeling, mede gelet op de door RMC op dit punt ingebrachte zienswijzen. De Raad geeft in hoofdstuk 6 zijn overwegingen omtrent het toerekenen van de overtreding. Vervolgens geeft de Raad in hoofdstuk 7 zijn overwegingen omtrent het opleggen van een boete, mede naar aanleiding van de zienswijze van RMC. Ten slotte volgt het dictum.

2 PROCEDURELE ASPECTEN

22. RMC geeft in haar zienswijze aan dat zij zich niet herkent in het beeld dat de NMa oproept in het Rapport en dat de procedurele regels in dit onderzoek zijn geschonden. Zij stelt dat de NMa, hoewel zij beschikt over zeer veel schriftelijke en digitale stukken, slechts een zeer beperkt aantal passages hieruit heeft gebruikt om in het Rapport te kunnen betogen dat er sprake is van mededingingsbeperkende afspraken. Zij stelt dat de NMa ten onrechte voor RMC ontlastende feiten heeft genegeerd. Deze manier van rapporteren doet geen recht aan de plicht van de NMa tot objectieve waarheidsvinding en ondermijnt een juiste beeldvorming inzake de vermeende overtredingen, aldus RMC. Het Rapport is niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen, waardoor de NMa in strijd heeft gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en met artikel 6 EVRM.

¹⁴ Onder de regio Rotterdam wordt in het Rapport verstaan: de gemeente Rotterdam en de omliggende gemeenten, zoals Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Zuidplas (waaronder Nieuwerkerk aan den IJssel), Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en Spijkenisse.

23. De Raad is van oordeel dat de Directie Mededinging zich, gelet op de omschrijving van het doel van het onderzoek, bij het toepassen van haar bevoegdheden heeft gehouden aan het evenredigheids- en proportionaliteitsbeginsel. Vervolgens wijst de Raad erop dat RMC niet stelt dat er ontlastende documenten zijn die niet aan het dossier zijn toegevoegd, maar dat zij stelt dat de Directie Mededinging niet alle ontlastende documenten in het Rapport heeft opgenomen.
24. De betrokken ondernemingen zijn, nadat het dossier ter inzage is gelegd, door de NMa in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken over de bevindingen van de Directie Mededinging zoals die zijn neergelegd in het Rapport en over de zich in het dossier bevindende documenten. Het staat de betrokken ondernemingen vrij om de zich in het dossier bevindende ontlastende feiten naar voren te brengen of te benadrukken. Ook kunnen zij ontlastende feiten die niet in het dossier zijn opgenomen, in hun zienswijzen naar voren brengen. Overigens merkt de Raad op dat RMC niet heeft gespecificeerd welke gegevens uit het dossier ten onrechte niet in het Rapport zijn opgenomen.
25. Tot slot wijst de Raad er op dat zowel de Mededingingswet als de Algemene wet bestuursrecht en de procedures die de NMa hanteert, erin voorzien dat door de Raad niet vooringenomen wordt gehandeld. Nadat het Rapport aan de betrokken ondernemingen is toegezonden, nemen de werkzaamheden in verband met de procedure van hoor en wederhoor ter voorbereiding van het besluit omtrent het opleggen van een sanctie een aanvang. De ambtenaren die bij deze werkzaamheden zijn betrokken, zijn niet betrokken geweest bij de opstelling van het Rapport en het daaraan voorafgaande onderzoek. Hiermee is een waarborg tegen vooringenomenheid gegeven.
26. Uit het bovenstaande volgt naar het oordeel van de Raad dat de zienswijze van RMC met betrekking tot de procedure geen doel treft.

3 CONTRACTUEEL TAXIVERVOER

3.1 Vormen van contractueel taxivervoer

27. In onderhavige zaak gaat het uitsluitend om gedragingen die betrekking hebben op opdrachten voor contractueel taxivervoer.¹⁵ Contractueel taxivervoer omvat in ieder geval de volgende vormen van vervoer: Wmo-vervoer, zittend ziekenvervoer, leerlingenvervoer,

¹⁵ Andere benamingen zijn: kleinschalig personenvervoer, contractuele taxidiensten, contractvervoer en doelgroepenvervoer. Voor zover het vervoer een aanvulling betreft op het openbaar vervoer waarbij meerdere “klanten” tegelijkertijd vervoerd worden wordt eveneens de term Collectief Aanvullend Vervoer (CAV) gehanteerd.

collectief vraagafhankelijk vervoer (hierna: CVV), AWBZ-vervoer¹⁶, bovenregionaal vervoer gehandicapten (hierna: Valys), Wsw-vervoer en zakelijk vervoer. Contractueel taxivervoer onderscheidt zich enerzijds van geregeld openbaar vervoer, zoals lijnbussen, en anderzijds van het straattaxivervoer.¹⁷

28. De bovengenoemde typen contractueel taxivervoer hebben de volgende kenmerken:

- Wmo-vervoer (voorheen Wvg-vervoer, op basis van de Wet vervoer gehandicapten) is vervoer van personen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het betreft vervoer van personen die niet zelfstandig per auto of openbaar vervoer kunnen reizen, zoals gehandicapten en ouderen. Wmo-vervoer wordt ook Collectief Aanvullend Vervoer (CAV) genoemd.
- Zittend ziekenvervoer of zorgvervoer is vervoer van zieke personen (verzekerden) met een taxi(bus) of rolstoelbus naar en van de plaats van een medische behandeling.
- Leerlingenvervoer is voor leerlingen van basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs die redelijkerwijs niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), ook bekend als Regiotaxi, is lokaal of regionaal taxivervoer van deur tot deur voor reizigers die hun taxi(bus) delen. Het is een vorm van openbaar vervoer die vooral geschikt is voor ouderen en mensen met een beperking die het reguliere openbaar vervoer niet kunnen gebruiken. CVV wordt ook ingezet als aanvulling op Wmo-vervoer.
- AWBZ-vervoer is medisch noodzakelijk vervoer van en naar een instelling van verzekerden voor dagbesteding. De basis hiervoor is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het vervoer wordt geregeld door zorginstellingen.
- Valys is vervoer voor sociaalrecreatieve doeleinden van personen met een mobiliteitsbeperking naar bestemmingen die meer dan 5 openbaar-vervoerzones vanaf het vertrekpunt zijn gelegen. De doelgroep is dezelfde als bij Wmo-vervoer.
- Wsw-vervoer, op basis van de Wet sociale werkvoorziening, is vervoer van werknemers van sociale werkplaatsen. Gemeenten zijn belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en subsidiëren de sociale werkplaatsen.
- Zakelijk vervoer is vervoer op contractbasis van werknemers of directieleden van bedrijven en (overheids)instellingen die, naar gelang de omvang van het contract, de opdracht aanbesteden.

29. Op het gebied van contractueel taxivervoer zijn landelijke, regionale en lokale taxiondernemingen actief. Het contractueel taxivervoer wordt uitgevoerd met taxi's, taxibussen en rolstoelbussen. Bij rolstoelvervoer kan er ook sprake zijn van een mengvorm

¹⁶ Voorbeelden hiervan zijn de Regiotaxi en de zogenaamde Hopper.

¹⁷ Dossierstuk 56, met kenmerk 7130/43: memo Bedrijfsgegevens en markt: Position Paper Kleinschalig Personenvervoer (2010 AVG-Movares i.o.v. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, bron: www.VNG.nl); Handreikingen voor hoogwaardig contractvervoer (2008 SEO in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat en KNV Taxi, bron: www.rijksoverheid.nl).

met valide passagiers. Taxiondernemingen kunnen relatief eenvoudig elke vorm van contractueel taxivervoer aanbieden.¹⁸

30. Opdrachtgevers voor contractueel taxivervoer zijn overheden, zorgverzekeraars, (zorg)instellingen en bedrijven.

3.2 Wijze van verkrijgen van opdrachten

31. Opdrachten voor contractueel taxivervoer worden in de regel gegund via aanbestedingen. In dit besluit wordt onder het begrip “aanbesteding” verstaan de procedure waarin opdrachtgevers openbaar of onderhands¹⁹ aanbieders van contractueel taxivervoer uitnodigen om een bieding uit te brengen voor een dienst die de opdrachtgever uitgevoerd wil zien. Door opdrachtgevers wordt veelal gebruik gemaakt van openbare aanbestedingen. De opdrachtgever beoogt met de aanbesteding door het oproepen van concurrentie de best mogelijke bieding te krijgen. De vereiste concurrentie brengt met zich dat verschillende ondernemingen zelfstandig hun inschrijf- en offertegedrag moeten bepalen.
32. De aanbestedingen kunnen een landelijk karakter hebben waarbij één opdracht wordt gegund²⁰ of waarbij meerdere opdrachten worden gegund indien het gebied van de aanbesteding is verdeeld in percelen.²¹ De meeste aanbestedingen hebben echter een regionaal of lokaal karakter vanwege de wettelijke verplichting van regionale en lokale overheden tot het laten uitvoeren van het vervoer. Ook bij regionale of lokale aanbestedingen kan de opdracht zijn opgedeeld in meerdere percelen. De duur van de uiteindelijk te gunnen opdrachten bedraagt doorgaans 1 tot 3 jaar.
33. Taxiondernemingen kunnen bij aanbestedingen zelfstandig of in combinatie inschrijven. In beginsel kunnen alle bedrijven die in het bezit zijn van een taxivergunning inschrijven op een aanbesteding. Daarnaast is onderaanneming een veelgebruikte vorm van samenwerking. De onderaannemers worden, voor zover de aanbestedende dienst dat vereist, bij de inschrijving kenbaar gemaakt aan de aanbestedende dienst ofwel na gunning van de opdracht gecontracteerd door de inschrijver aan wie de opdracht gegund is. Door het gebruik van

¹⁸ In zaak 6957/Veolia – CDC-Transdev is geconcludeerd dat het type vervoer geen bepalende factor is voor de beslissing van een aanbieder wel of niet mee te bieden op een contract. Taxiondernemingen kunnen naar eigen zeggen alle soorten taxivervoer verrichten. Zie het besluit van de Raad in zaak 6957 van 9 december 2010, randnummers 107 tot en met 110. Dit beeld wordt bevestigd door de analyse van inschrijvingen op aanbestedingen in de regio Rotterdam waaruit blijkt dat taxiondernemingen voor verschillende typen vervoer inschrijven. Zie hiervoor dossierstuk 56, met kenmerk 7130/43: memo Bedrijfsgegevens en markt.

¹⁹ Onder onderhandse aanbestedingen worden ook wel ‘offerteprocedures’ begrepen, waarbij de opdrachtgever, al dan niet gelijktijdig, minimaal twee aanbieders benadert.

²⁰ Een voorbeeld voor een landelijke opdracht verstrekt aan één onderneming is het Valys-contract.

²¹ Een voorbeeld is een groot aantal opdrachten die Achmea heeft gegeven aan verschillende taxiondernemingen die in 2008 hebben ingeschreven op 113 percelen in Nederland voor zittend ziekenvervoer van Achmea.

onderaannemers zijn grote landelijke taxiondernemingen, als aanbieders van contractueel taxivervoer, eerder in staat in te schrijven op aanbestedingen en deze door, voornamelijk lokale, taxiondernemingen uit te laten voeren.

34. Veelal stelt de aanbestedende dienst als voorwaarde voor inschrijving, dat men beschikt over voldoende financiële draagkracht en over kennis van wegen en straten in de desbetreffende regio. Vervolgens kunnen aanbieders concurreren op prijs en op aspecten van kwaliteit, waarbij de hoogte van de prijs doorgaans zwaarder wordt meegewogen bij de bepaling aan wie gegund wordt. In het aanbestedingsbestek wordt nader invulling gegeven aan de eisen betreffende deze concurrentieparameters. De inschrijver die het hoogste scoort op de in het aanbestedingsbestek genoemde eisen, krijgt de opdracht gegund voor het rijden van contractueel taxivervoer. Bij grote opdrachten bestaat de mogelijkheid dat kleinere aanbieders niet aan de selectiecriteria voldoen wat betreft de financiële draagkracht van de onderneming of de eis referenties van eerdere opdrachtgevers te overleggen.

3.3 Aanbieders van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam

35. Zoals bij randnummers 13 en 14 is vermeld, boden RMC en (tot haar faillissement) IJsselsteden contractueel taxivervoer aan in de regio Rotterdam. Dit is voor de relevante periode weergegeven in het overzicht in Bijlage I, die onderdeel uitmaakt van dit besluit. In deze regio zijn naast de betrokken ondernemingen andere lokale, regionale en landelijke marktpartijen actief op het gebied van contractueel taxivervoer. Uit navraag onder diverse lokale, regionale en landelijke taxiondernemingen blijkt dat RMC, Connexion, De Vier Gewesten B.V., BIOS-groep (waaronder ZCN Totaalvervoer en Taxicentrale Middelburg die onder eigen naam opereren), Taxi Bakker B.V., IJsselsteden en Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN) belangrijke spelers zijn in de provincie Zuid-Holland. Een analyse van inschrijvers op aanbestedingen in de regio Rotterdam bevestigt dat deze taxiondernemingen ook in de regio Rotterdam een belangrijke positie innemen, met uitzondering van PZN die in de regio Rotterdam niet bijzonder actief blijkt te zijn.²²
36. Het onderzoek van de Directie Mededinging omvat in de periode vanaf medio 2006 tot oktober 2010 24 aanbestedingen.²³ Uit analyse van deze aanbestedingen blijkt dat RMC en/of IJsselsteden bij 15 van de 24 aanbestedingen heeft ingeschreven, en dat RMC en/of IJsselsteden bij 10 van deze 15 aanbestedingen gegund hebben gekregen. Verder blijkt dat er bij de meeste aanbestedingen waarop RMC en/of IJsselsteden heeft ingeschreven niet meer

²² Dossierstuk 56, met kenmerk 7130/43: memo Bedrijfsgegevens en markt.

²³ De Directie Mededinging heeft in het kader van het onderzoek inlichtingen ingewonnen bij marktpartijen [vertrouwelijk] en opdrachtgevers van contractueel taxivervoer (Zilveren Kruis Achmea, de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard, de gemeente Krimpen aan den IJssel, de gemeente Rotterdam, de gemeente Capelle aan den IJssel, stichting ASVZ, stichting Pameijer, UVIT verzekeren en stichting Laurens Antonius Binnenweg).

dan vier inschrijvers waren. Voor een overzicht van aanbestedingen in de voor het onderhavige besluit relevante periode (zoals hieronder nog zal blijken, van 18 december 2009 tot 27 augustus 2010), verwijst de Raad naar het overzicht in Bijlage I van het onderhavige besluit.

4 FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN TEN AANZIEN VAN DE GEDRAGINGEN

37. In het onderhavige hoofdstuk stelt de Raad de aanloop naar, de totstandkoming van en de inhoud van de overeenkomst vast, die RMC en IJsselsteden op 18 december 2007 hebben ondertekend. Vervolgens gaat de Raad in op de feiten en omstandigheden in de periode na de ondertekening van de overeenkomst.
38. Deze feiten en omstandigheden, die de Raad op basis van het Rapport, het dossier en de zienswijze van RMC vaststelt, vormen de basis voor de juridische beoordeling in dit besluit.

4.1 De aanloop naar de totstandkoming van de overeenkomst

39. IJsselsteden en RMC nemen in 2007 onderling contact op naar aanleiding van het faillissement van de Capelse Taxi Centrale (een 100% dochteronderneming van IJsselsteden), de onderneming die op dat moment de aanbesteding voor leerlingenvervoer in Capelle aan den IJssel uitvoerde.²⁴ RMC had de uitvoering van dit contract op verzoek van de gemeente Rotterdam overgenomen. Aangezien IJsselsteden in opdracht van de Capelse Taxi Centrale reeds het daadwerkelijke vervoer deed en omdat RMC deze opdracht niet zelfstandig kon uitvoeren, vroeg RMC aan IJsselsteden of zij het vervoer wilde blijven uitvoeren.
40. Medio 2007 wordt het WMO-vervoer in Capelle aan den IJssel aanbesteed. IJsselsteden wilde graag op deze aanbesteding inschrijven, maar zij had een partner nodig om aan de solvabiliteitsis te voldoen.²⁵ IJsselsteden heeft toen samen met BTR (waarvan RMC meerderheidsaandeelhouder is) ingeschreven.²⁶ Nadat IJsselsteden (samen met BTR) de opdracht gegund kreeg, is de Capelse Vervoers Groep opgericht. Hierin hadden BTR en IJsselsteden [vertrouwelijk] een aandeel van [vertrouwelijk]%.²⁷

²⁴ Dit verklaart de heer [C], dossierstuk 17, met kenmerk 7130/24, pagina 5.

²⁵ Dossierstuk 17, met kenmerk 7130/24, verklaring de heer [C], pagina 5.

²⁶ BTR Groep B.V. is een joint venture van RMC ([vertrouwelijk]% aandeel) en Bios Rijnmond Beheer B.V. ([vertrouwelijk]aandeel) en is in 2007 opgericht.

²⁷ Dossierstuk 17, met kenmerk 7130/24, verklaring de heer [C], pagina 5.

41. Vervolgens neemt RMC eind 2007 contact op met IJsselsteden om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.²⁸ Aanleiding hiervoor was het conflict tussen IJsselsteden en RTC, zoals aangegeven in één van de overwegingen van de overeenkomst van 18 december 2007:

"Er is per 1 april 2007 een conflict ontstaan tussen RTC en IJsselsteden inzake de uitvoering van het Valys-vervoer".²⁹

42. Op 17 december 2007 hebben RMC en IJsselsteden overleg gehad over de samenwerkingsovereenkomst. De Raad leidt dit af uit de interne e-mail van de heer [A] (RMC) van 17 december 2007 aan onder andere de heer [B] (RMC), met als bijlage de "Conceptsamenwerkingsovereenkomst IJsselsteden":

"Ik heb vanmiddag een vervolggesprek gehouden met IJsselsteden en alle onderwerpen doorgesproken, t/m aanbesteding VOM, etc. Ik wil dit verhaal morgenochtend doorsturen aan [C] en [D] en liefst die zelfde dag nog laten tekenen".³⁰

De bij deze e-mail gevoegde conceptovereenkomst bevat dezelfde bepalingen die later in de overeenkomst van 18 december 2007 onder artikel 8 en de eerste twee alinea's van artikel 9 zijn neergelegd.

43. Hierna vinden er nog enkele contacten plaats tussen RMC en IJsselsteden over de samenwerkingsovereenkomst. Op 18 december 2007 zendt de heer [A] RMC) per e-mail een gecorrigeerde versie van de conceptovereenkomst. De Raad leidt dit af uit de e-mail van de heer [A] aan de heer [C] en de heer [D] (beiden van IJsselsteden) en in afschrift aan de heer [B] (RMC):

"[vertrouwelijk], [vertrouwelijk], (NMa: de heren [C] en [D])

Hierbij de versie die eigenlijk aan jullie had moeten versturen.

Deze heb ik aangepast op basis van mijn tel. Gesprekje met [vertrouwelijk].

Ik hoor graag verder van jullie.

Mvrgr.

[A]".³¹

²⁸ Dossierstuk 17, met kenmerk 7130/24, verklaring de heer [C].

²⁹ RMC raakte het Valys-vervoer kwijt aan Connexxion. Uiteindelijk is IJsselsteden in opdracht van Connexxion delen van dit vervoer gaan rijden, hetgeen tot een conflict tussen RTC (waarbij IJsselsteden was aangesloten) en IJsselsteden leidde.

³⁰ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41, bijlage 2.

³¹ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41, bijlage 4.

De bij deze e-mail gevoegde conceptovereenkomst bevat een aanvulling op de eerste twee alinea's van punt 9. Aan punt 9 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Indien derhalve bestaande contracten van één der Partijen onderwerp wordt van aanbesteding, zal de ander partij (en aan haar gelieerde ondernemingen) zich onthouden van inschrijving en zich tevens onthouden van het aanbieden/verlenen van diensten aan derde partijen, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de partij wiens contract onderwerp is van aanbesteding, zulks met en boete van 0,5% van de jaarcontractwaarde per dag vanaf de dag dat de partij diensten gaat leveren aan derden.”

44. Op 18 december 2007 wordt er op verzoek van IJsselsteden vervolgens een vierde alinea toegevoegd aan artikel 9 van de overeenkomst. De Raad leidt dit af uit de tweede e-mail die de heer [A] op 18 december 2007 zendt aan de heer [C] en de heer [D] (beiden van IJsselsteden) en in afschrift aan de heer [B] (RMC):

*“Beste [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], (NMa: de heren [C] en [D])
Ik heb jullie laatste wens verwerkt in een extra alinea bij punt 9.
Tevens nog even een enkele tekstfout (o.a bij de tenaamstelling) verbeterd.
Als jullie morgen laten weten of we er dan zoals verwacht definitief uit zijn, dan is het voor ons allen misschien leuk om nog voor de Kerst te tekenen.
Mvrgr.
[A]”.*³²

De bij deze e-mail gevoegde conceptovereenkomst bevat een aanvulling van een vierde alinea aan artikel 9. Aan artikel 9 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Door juist dit soort zaken nadrukkelijk af te spreken beogen Partijen een stevig fundament onder de samenwerking te leggen. Voor het geval een derde een contract gegund krijgt dat thans deel uit maakt van het pakket van één der Partijen, dan zullen Partijen gezamenlijk in overleg treden met de nieuwe contracthouder omtrent de condities waaronder desgevraagd diensten aangeboden gaan worden aan de nieuwe contracthouder. Op deze wijze wensen partijen niet onderling uitgespeeld te worden.”

4.2 De overeenkomst

45. In de Samenwerkingsovereenkomst zoals op schrift gesteld op 18 december 2007 (hierna: de Overeenkomst) is als overweging opgenomen dat RMC en IJsselsteden de wens hebben om

³² Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41, bijlage 5.

de huidige en toekomstige samenwerking in een overeenkomst vast te leggen. De Overeenkomst is als Bijlage II aan het onderhavige besluit gehecht.

46. Partijen stellen dat zij *"reeds enige tijd samenwerkingsverbanden hebben op het gebied van het kleinschalig personenvervoer en [...] mede gelet op recente marktontwikkelingen de wens hebben om de huidige en de toekomstige samenwerking in een overeenkomst vast te leggen."* Met betrekking tot de huidige samenwerking wordt onder de punten 1 tot en met 5 van de Overeenkomst zogenaamde *"status informatie"* in ogenschouw genomen. Deze statusinformatie betreft de verhouding van partijen tot de BTR Groep, de oprichting van de Capelse Vervoer Groep B.V., de relatie tot RTC en het belangenconflict tussen RTC en IJsselsteden over de uitvoering van het Valysvervoer.
47. Voorts nemen partijen in punt 5 in ogenschouw, dat zij *"na ampele overweging, hebben geconcludeerd grote belangen toe te kennen aan een regionale samenwerking, waarvan de uitgangspunten en condities worden vastgelegd in de onderhavige samenwerkingsovereenkomst."*
48. Punten 6 en 7 betreffen overname van het contract Leerlingenvervoer met de gemeente Capelle aan den IJssel in verband met een probleem met de Capelse Taxi Centrale (100% dochter van IJsselsteden). RMC wil dit per 1 januari 2008 overnemen, terwijl de dagelijkse uitvoering in handen blijft van IJsselsteden.
49. Met betrekking tot de toekomstige situatie komen RMC en IJsselsteden in de punten 8 tot en met 11 het volgende overeen.

8. Partijen m.b.t. toekomstige aanbestedingen hun wederzijdse thuismarkten als volgt wensen te definiëren, te weten:

IJsselsteden:

Capelle a/d IJssel, Zevenhuizen, Nieuwerkerk, Krimpen, Krimpenerwaard

RMC:

Groot Rotterdam (inclusief Hoek van Holland) en Albrandswaard

9. Beide partijen bij aanbestedingen op het gebied van het kleinschalig personen vervoer op de onder ad 8) genoemde eigen thuismarkt in principe zelfstandig zullen inschrijven indien zij reeds houder zijn van het contract dat aanbesteed wordt., tenzij uiteraard een gezamenlijke inschrijving de kans op succes aanzienlijk vergroot.

De andere partij zal zich onthouden van inschrijving, maar wel als “most preferred partner” worden ingeschakeld indien de eigen organisatie de uitvoering van het complete contract niet aan kan of aan wil. (RMC heeft als voorbeeld IJsselsteden de mogelijkheid geboden om desgewenst een aantal bussen te kunnen leveren in geval van aanbesteding van het VoM contract.)

Indien derhalve bestaande contracten van één van de Partijen onderwerp wordt van aanbesteding, zal de andere partij (en aan haar gelieerde ondernemingen) zich onthouden van inschrijving en zich tevens onthouden van het aanbieden/verlenen van diensten aan derde partijen, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de partij wiens contract onderwerp is van aanbesteding, zulks met een boete van 0,5% van de jaarcontractwaarde per dag vanaf de dag dat de partij diensten gaat leveren aan derden.

Door juist dit soort zaken nadrukkelijk af te spreken beogen Partijen een stevig fundament onder de samenwerking te leggen. Voor het geval een derde een contract gegund krijgt dat thans deel uit maakt van het pakket van één der Partijen, dan zullen Partijen gezamenlijk in overleg treden met de nieuwe contracthouder omtrent de condities waaronder desgevraagd diensten aangeboden gaan worden aan de nieuwe contracthouder. Op deze wijze wensen Partijen niet onderling uitgespeeld te worden.

10. Indien op de onder ad 8) genoemde thuismarkten een contract in de aanbesteding komt waarvan een derde op dat moment houder is, dan treden partijen in overleg. Dit overleg kan als uitkomst hebben dat een gezamenlijke inschrijving volgt, dan wel dat beide partijen hun eigen weg gaan en beide afzonderlijk inschrijven.
11. Partijen over en weer geen actieve acquisitie plegen m.b.t. elkaanders klanten c.q. opdrachtgevers.

50. Kern van de afspraak is dat RMC en IJsselsteden elkaars (in punt 8 omschreven) thuismarkten respecteren; toekomstige opdrachten zullen dienovereenkomstig worden verdeeld. In het geval dat één van de partijen al houder is van een contract dat opnieuw wordt aanbesteed, zal de ander niet (zelfstandig)inschrijven. In het geval dat een derde houder is van een contract dat opnieuw wordt aanbesteed, treden partijen met elkaar in overleg over gezamenlijke dan wel afzonderlijke inschrijving. Actieve acquisitie met betrekking tot elkaars klanten of opdrachtgevers wordt eveneens uitgesloten.

51. Aanvullend komen partijen overeen dat zij hun diensten niet zonder toestemming van de ander zullen aanbieden aan derden (op straffe van een boete) en dat bij verkrijging door een derde zij daarmee gezamenlijk in overleg treden, om bij het eventueel verlenen van diensten voor deze derde onderneming niet tegen elkaar te worden uitgespeeld.
52. Daarnaast voorziet de overeenkomst erin dat RMC en IJsselsteden in overleg gezamenlijk inschrijven als dit de kans op succes vergroot en dat men elkaar als *most preferred partner* kan inschakelen als de capaciteit of de wil ontbreekt om een opdracht (in het thuisgebied) geheel zelf uit te voeren.
53. In de punten 12 tot en met 14 worden - in aansluiting op de punten 1 tot en met 4 – enkele specifieke aspecten in relatie tot RTC, de BIOS-groep en Connexxion behandeld. Hoewel deze overwegingen op toekomstige gedrag zien, bevatten zij geen harde verplichtingen en doen zij niet toe of af aan het bij randnummer 49 aangehaalde deel van de Overeenkomst. In de Overeenkomst is geen bepaling inzake de duur ervan opgenomen.
54. De Overeenkomst wordt op 18 december 2007 ondertekend door de heren [C] en [D] namens IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. en door de heer [A] namens Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.³³
55. De heer [C], destijds [leidinggevende] van de IJsselsteden Beheers Groep B.V., verklaart over de ondertekening van de Overeenkomst dat het niet uitmaakte welke aanduiding voor IJsselsteden in de Overeenkomst is opgenomen en dat het de bedoeling was dat de Overeenkomst voor de complete IJsselsteden groep (IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. en IJsselsteden Beheers Groep B.V.) zou gelden.³⁴

4.3 Vervolg op de totstandkoming van de Overeenkomst

56. In de hierna volgende randnummers worden de relevante feiten en omstandigheden volgend op de totstandkoming van de overeenkomst beschreven. Hieruit blijkt dat de betrokken ondernemingen na de totstandkoming van de overeenkomst contact met elkaar hebben gehad in het kader van aanbestedingen in de regio Rotterdam. Deze contacten illustreren dat de overeenkomst niet slechts op papier bestond, maar dat RMC en IJsselsteden ook uitvoering hebben gegeven, dan wel trachtten te geven, aan de overeenkomst. Daarnaast blijkt uit het overzicht van aanbestedingen in Bijlage I dat RMC en IJsselsteden doorgaans niet beide inschreven op aanbestedingen in de regio Rotterdam.

³³ Dossierstuk 60, met kenmerk 7130/42, bijlage 1, afkomstig van bedrijfsbezoek bij RMC/RTC.

³⁴ Dossierstuk 17, met kenmerk 7130/24, pagina 5.

(i) Aanbesteding Leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2008

57. In februari 2008 publiceert de gemeente Capelle aan den IJssel het bestek voor leerlingenvervoer in Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel behoort tot de thuismarkt van IJsselsteden. Zoals beschreven bij randnummer 39 werd dit contract tot die tijd tijdelijk door RMC (met behulp van IJsselsteden) uitgevoerd, nadat de oorspronkelijke vervoerder, de Capelse Taxi Centrale, failliet ging.
58. In een intern memo, 'Toelichting op de agenda van woensdag 19 maart 2008', van de heer [B] (RMC) ten behoeve van een vergadering van RMC wordt ingegaan op deze aanbesteding. Hierbij wordt verwezen naar een afspraak over een 'gebiedsverdeling' met IJsselsteden en het overleg daarover tussen de betrokken ondernemingen. De Raad leidt uit het memo af dat RMC en IJsselsteden contact met elkaar hebben over het inschrijven op deze aanbesteding en dat RMC daarbij rekenschap geeft van een afspraak met IJsselsteden:

"- Leerlingenvervoer Capelle a/d IJssel

Toelichting

Sinds kort staat dit contract op naam van RMC en wordt uitgevoerd door de CTC (IJsselsteden Taxi Combinatie) die het al een paar jaar reed. Na de zomer gaat dus een nieuwe contractperiode in. RMC heeft een afspraak over gebiedsverdeling met de IJsselsteden Taxi Combinatie. Daarin past inschrijven niet direct. Toch is het zeer wel mogelijk dat zij zelf niet gaan inschrijven en ons dit dezer dagen laten weten. In die situatie zijn zij mogelijk bereid wel delen van het contract te rijden omdat wij daartoe toch niet voldoende eigen voertuigen hebben. Er is in elk geval goed en open contact hierover. (Onderstreping NMa)

Weet dat we het WMO vervoer gezamenlijk (NMa: Via de Capelse Vervoer Groep) doen in Capelle. Vooral een papieren kwestie. Zij rijden en regisseren en wij pakken wat snippertjes mee." ³⁵

59. Dat RMC rekening hield met de Overeenkomst wordt bevestigd door een e-mail van 20 mei 2008 van de [werknemer] van RMC aan een derde onderneming³⁶, waarbij de heer [A] (RMC) in de CC is opgenomen.

"Ik heb nog even met [vertrouwelijk]³⁷ gehad over het leerlingenvervoer Capelle, want ik kon mij niet meer precies de afspraken herinneren. Volgens Henk zouden wij niet inschrijven, tenzij de positie van IJsselsteden naar onze mening niet sterk genoeg is. Dat lijkt nu het geval te zijn. Verder zijn wij natuurlijk nu contracthouder. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het leerlingenvervoer Capelle niet echt iets is waar wij strategisch op zitten te wachten. Wij zullen

³⁵ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41, bijlage 7.

³⁶ Bios Rijnmond Beheer B.V.

³⁷ Dit betreft de heer [A] (RMC).

*dan ook inschrijven voor een prijs waar we het graag voor willen hebben."*³⁸ (Onderstreping NMa)

60. Op 28 mei 2008, respectievelijk 29 mei 2008 schrijven zowel RMC als IJsselsteden Beheersgroep B.V. in. IJsselsteden krijgt deze opdracht gegund.
61. De Raad stelt allereerst vast dat de betrokken ondernemingen contact hebben gehad over de aanbesteding Leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel. Dit blijkt uit het hiervoor besproken memo van RMC en de interne e-mail van RMC. Voorts blijkt uit de tekst van deze documenten dat RMC zich rekenschap geeft van de afspraak die zij met IJsselsteden heeft over het voeren van (voor)overleg bij het inschrijven op aanbestedingen. In de bijzondere situatie van deze aanbesteding zijn de gedragingen van RMC en IJsselsteden in het kader van deze aanbesteding naar het oordeel van de Raad niet zo te duiden, dat zij afstand namen van de Overeenkomst.

(ii) Aanbesteding WMO AlRiBa

62. Op 11 maart 2008 publiceren de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht het aanbestedingsdocument voor WMO AlRiBa. De gemeente Albrandswaard behoort volgens de Overeenkomst tot de thuismarkt van RMC. Ten tijde van deze aanbesteding voerde RMC het contract in de gemeente Albrandswaard uit, nadat de oude gecontracteerde vervoerder van het contract was 'afgezet' vanwege slechte prestaties. Taxi Bakker was ten tijde van deze aanbesteding zittende vervoerder ten aanzien van het contract in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht.³⁹ RMC schrijft op 14 april 2008 conform de Overeenkomst in. IJsselsteden schrijft niet in, eveneens conform de Overeenkomst.⁴⁰ Een derde, Connexxion, krijgt de opdracht gegund.

(iii) Aanbesteding Buiten bestek leerlingen Capelle aan den IJssel

63. In augustus 2008 vraagt de gemeente Capelle aan den IJssel, door middel van één e-mail, gericht aan zowel RMC als aan IJsselsteden, een offerte aan voor het vervoer van zes leerlingen uit Capelle aan den IJssel⁴¹ (de zogenoemde 'Buiten bestek leerlingen') naar scholen in Zoetermeer, Ermelo, Spijkenisse en Breda:

*"Hallo heren,
Graag voor de volgende zes leerlingen een offerte".*⁴²

³⁸ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41, bijlage 8.

³⁹ Dossierstuk 37, met kenmerk 7130/59.

⁴⁰ Dossierstuk 37, met kenmerk 7130/59.

⁴¹ Het gaat hier om andere leerlingen dan die van de aanbesteding als genoemd bij randnummer 57–61.

⁴² Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41: verslag van opname, digitaal document nr. 10, afkomstig van bedrijfsbezoek IJsselsteden.

64. RMC neemt naar aanleiding van dit offerteverzoek contact op met IJsselsteden. In een e-mailwisseling op 18 en 19 augustus tussen de [werknemer] van RMC en de heer [C] (IJsselsteden) verwijzen beiden ondernemingen naar de Overeenkomst.

65. Allereerst zendt RMC een e-mail aan IJsselsteden:

"[vertrouwelijk],
Dit zijn leerlingen die wij altijd al reden. Ik neem aan dat wij deze kunnen behouden.
(..)
Mvgr
[vertrouwelijk]"

66. Hierop reageert IJsselsteden met de e-mail (Onderstreping NMa):

"[vertrouwelijk],
(..)
De afspraak was ieder eigen gebied dus dit valt onder mij ik heb Breda al gegund gekregen dus gaarne niet onder de prijs door er licht ook een offerte voor de andere ritten en den haag gaat ook apart
(..)
Dus conform afspraak graag.
Ik stuur cc [vertrouwelijk] (NMa: de heer [A] van RMC).
[C] "

67. RMC kan zich niet vinden in de reactie van IJsselsteden en zendt wederom een e-mail aan IJsselsteden (Onderstreping NMa):

"Beste [vertrouwelijk],
Afspraak was, ieder eigen gebied met uitzondering van de contracten die wij al hadden (en voor zover bekend was). Die rit naar Breda en Spijkenisse en Zoetermeer doen wij al jaren. (..)
Dus wij hebben recht op de ritten Capelle. Ben jij het er niet mee eens, dan offreren we gewoon onafhankelijk van elkaar.
Met vriendelijke groet,
[vertrouwelijk]"

68. Vervolgens reageert IJsselsteden met de e-mail (Onderstreping NMa):

"[vertrouwelijk]
Dit is wel de afspraak ik rij die zoetermeer ed en voorts al tijden tot vorig jaar hebben juli ze gereden daarna is er een overeenkomst de datum 18 dec 2007 gemaakt als juli [NMa: jullie]
Die afspraak niet kunnen of willen nakomen dan is het ons ook vrij om op vom in te schrijven
ik denk dat dit niet de bedoeling is van onze afspraken.

*Met vriendelijke groet,
[vertrouwelijk]"*

69. Ten slotte zendt RMC op haar beurt aan IJsselsteden de volgende e-mail (Onderstreping NMa):

*"Beste [vertrouwelijk],
Breda, Spijkenisse rijden wij al meerdere jaren achter elkaar, is dus gewoon ons werk. Ik neem aan dat jij dus het contract respecteert, zoals wij dat ook altijd gedaan hebben.
Met vriendelijke groet,
[vertrouwelijk]"*⁴³

70. De Raad stelt vast dat RMC en IJsselsteden bij deze aanbesteding onderling contact hebben gehad in het kader van de Overeenkomst, waarbij RMC en IJsselsteden discussie hebben over de inhoud van de gemaakte afspraken. Niet alleen verwijst IJsselsteden daarbij letterlijk naar de Overeenkomst, ook dringt zij aan op het respecteren van bestaande contracten.
71. RMC stelt in haar zienswijze dat het hier geen aanbesteding betreft, maar een verzoek van de gemeente aan RMC en IJsselsteden om gezamenlijk een offerte in te dienen. Dit blijkt volgens RMC uit de e-mail die de gemeente naar beide ondernemingen heeft verzonden. In dit geval voerden beiden ondernemingen reeds het vervoer uit en waren zij derhalve de aangewezen partij voor dit meerwerk. Het betreft hier naar de mening van RMC geen afspraak die binnen de definitie van de Overeenkomst zoals omschreven in het Rapport valt.
72. De Raad stelt voorop dat een offerteaanvraag waarbij twee of meer ondernemingen kunnen reageren door de Raad is te kwalificeren als een (onderhandse) aanbesteding.⁴⁴ Uit de e-mail van de gemeente blijkt naar het oordeel van de Raad niet dat het hier om het indienen van één gezamenlijke offerte ging. Dat de betrokken ondernemingen het verzoek van de gemeente ook niet als zodanig hebben opgevat, blijkt uit de onderlinge e-mailwisseling. Integendeel, RMC en IJsselsteden refereren daarin aan de Overeenkomst en spreken elkaar juist aan op het feit dat zij overwegen om afzonderlijk een offerte in te dienen. Hieruit leidt de Raad af dat de betrokken ondernemingen nimmer van plan waren om één gezamenlijke offerte in te dienen.

(iv) Aanbesteding Vervoer op Maat Rotterdam 2008

73. Op 18 juli 2008 doet de gemeente Rotterdam een aankondiging van een aanbesteding voor Collectief Aanvullend Vervoer (hierna: VOM 2008). Dit contract werd tot die tijd uitgevoerd door RMC. Rotterdam behoort ook tot de thuismarkt van RMC. VOM 2008 wordt in de

⁴³ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41, bijlagen 10 en 23.

⁴⁴ Zie randnummer 31 van het onderhavige besluit.

Overeenkomst als voorbeeld genoemd van een situatie waarin RMC IJsselsteden als *most preferred partner* zal kunnen inschakelen:

"RMC heeft als voorbeeld IJsselsteden de mogelijkheid geboden om desgewenst een aantal bussen te kunnen leveren in geval van aanbesteding van het VoM contract."

74. In de periode voorafgaand aan het bekendmaken door de gemeente Rotterdam van de besteisen voor deze aanbesteding, wordt intern bij RMC al gespeculeerd over deze besteisen. Hieruit blijkt dat RMC vanwege het belang dat dit contract voor haar heeft zo min mogelijk andere aanbieders, waaronder IJsselsteden, als mogelijke inschrijver op het VOM 2008 wil hebben. De Raad leidt hieruit ook af dat IJsselsteden door RMC (in principe) als een concurrent wordt gezien. De Raad verwijst hiervoor naar een interne e-mail gedateerd 15 augustus 2007 van de [werknemer] van RMC, waarin staat:

"Citaat uit de aanbesteding ROG-Gemeente: inschrijver dient een referentie te overleggen die naar aard (CVV-vervoer) en omvang (700.000 zones per jaar) vergelijkbaar is met de huidige opdracht. Niet toegestaan om meerdere referenties op te tellen, het dient te gaan om 1 opdracht."

*Leuk voor de aanbesteding VOM met bijv. minimaal 1.500.000 zones per jaar 1 opdracht als referentie. Dit moet in de aanbesteding om bijv. IJsselsteden te kunnen weren."*⁴⁵

75. Dat RMC dit contract graag wilde behouden, blijkt onder andere uit de verklaringen van de heer [B] (RMC):

*"De aanbesteding Vervoer op Maat is namelijk cruciaal voor het voortbestaan van RMC."*⁴⁶

76. Op 9 september 2008 heeft RMC ingeschreven op de aanbesteding VOM 2008 met IJsselsteden als onderaannemer. Op 20 oktober 2008 heeft de gemeente Rotterdam aan RMC bekend gemaakt dat zij voornemens is aan RMC de opdracht te verlenen.⁴⁷

77. In april 2009 volgt een e-mailwisseling tussen RMC en IJsselsteden over de uitkomst van de aanbesteding VOM 2008:⁴⁸

*"Goedemiddag [vertrouwelijk] (NMa: de heer [A] van RMC),
Tot op dit moment hebben wij nog geen enkel teken van leven gezien van de kant van Connexion aangaande het Achmea Zittend Ziekenvervoer in Rotterdam. (..) Dit impliceert dan wel dat wij, volgens afspraak, per 1 mei a.s. mee gaan rijden met de afgesproken 10*

⁴⁵ Dossierstuk 60, met kenmerk 7130/42, bijlage 15.

⁴⁶ Dossierstuk 3, met kenmerk 7130/8, verklaring de heer [B], pagina 3.

⁴⁷ Dossierstuk 60, met kenmerk 7130/42, bijlagen 7 en 8.

⁴⁸ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41, bijlage 12.

voertuigen in het VOM project. Met wie of wanneer kunnen hier concrete afspraken over gemaakt worden?

Met groet,

[C]

[D]" (NMa: beiden [leidinggevende] van IJsselsteden)

78. Hierop reageert RMC met de volgende e-mail:

"[vertrouwelijk], [vertrouwelijk], (NMa: de heren [C] en [D] van IJsselsteden)

Ik heb tijdens de opening van jullie schadeafdeling nadrukkelijk met Ron afgesproken dat de definitieve keuze nu gemaakt is en dat we nu niet meer gaan veranderen. Wij moeten immers naar de opdrachtgever VOM wel onze zaken voor elkaar hebben en wij hebben de uren en wagens inmiddels toebedeeld aan [vertrouwelijk].

(..)

Met vriendelijke groet,

[A]" (NMa: RMC)

79. IJsselsteden reageert vervolgens als volgt:

"Goedemorgen [vertrouwelijk] (NMa: de heer [A] van RMC),

(..) *Wij hebben begrip voor jullie situatie en begrijpen ook dat er, na wisselingen van de wacht aan de Keenstraat⁴⁹, veranderingen zijn ontstaan. Deze veranderingen kunnen er volgens ons echter niet toe leiden dat wij met lege handen achter blijven. Volgens ons zijn wij de in jullie offerte met naam genoemde onderaannemer waarmee de RMC destijds op deze aanbesteding VoM heeft ingeschreven. Deze afspraak volgde destijds voort uit onze toezegging om niet zelf of in combinatie met een of meerdere andere partijen op dit project in te schrijven. Ook is de RMC schriftelijke contractuele afspraken met ons aangegaan om een (gedeelte) van het VoM project i.c.m. met de RMC uit te voeren.*" (Onderstreping NMa)

80. De Raad stelt vast dat de betrokken ondernemingen bij de inschrijving op de aanbesteding VOM 2008 conform de Overeenkomst hebben gehandeld. Omdat VOM 2008 tot de thuismarkt van RMC behoort en RMC reeds houder was van het contract, heeft IJsselsteden zich onthouden van inschrijving en daarbij, ook conform de Overeenkomst, haar diensten niet aangeboden aan een derde, in dit geval Connexxion. Daarnaast stelt de Raad vast dat IJsselsteden ook na gunning RMC aan de Overeenkomst herinnert en refereert aan de afspraken die zijn neergelegd in de Overeenkomst. Immers, IJsselsteden spreekt van "onze toezegging om niet zelf of in combinatie met een of meerdere andere partijen op dit project in te schrijven." Over de rol van IJsselsteden als onderaannemer, bestaat tussen partijen kennelijk onenigheid, maar dit doet niet af aan de strekking van de Overeenkomst.

⁴⁹ RMC en RTC zijn aan de Keenstraat in Rotterdam gevestigd.

(v) Aanbesteding Leerlingenvervoer Nieuwerkerk aan den IJssel

81. Op 27 april 2009 doet de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel een aankondiging van een aanbesteding voor leerlingenvervoer in haar gemeente. Deze gemeente behoort, volgens de Overeenkomst, tot de thuismarkt van IJsselsteden. IJsselsteden was ook reeds houder van dat contract.⁵⁰ Conform de Overeenkomst schrijft IJsselsteden in en RMC niet. IJsselsteden krijgt de opdracht gegund.

(vi) Leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel

82. Op 13 januari 2010 verzendt de gemeente Krimpen aan den IJssel de aankondiging van de Aanbesteding voor Leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel, die bestaat uit twee percelen: ten noorden van de Maas en ten zuiden van de Maas. Uit de Overeenkomst blijkt dat Krimpen aan den IJssel behoort tot de thuismarkt van IJsselsteden.
83. Dat RMC er rekening mee houdt dat Krimpen aan den IJssel tot de thuismarkt van IJsselsteden behoort en er onderling overleg nodig is, leidt de Raad af uit een interne e-mail van 1 februari 2010 van de [vertrouwelijk] van RMC aan de heer [A] (RMC):
- "[vertrouwelijk] (NMa: de heer [A] van RMC),
Voor het leerlingenvervoer Krimpen, dit ligt in het aanbestedingsgebied van IJsselsteden. Ik neem aan dat jij nog gaat overleggen met de vrienden." ⁵¹ (Onderstreping NMa)
84. RMC en IJsselsteden hebben over deze aanbesteding op 8 maart 2010 onderling contact gehad. Dit blijkt uit de email van 8 maart 2010 die de heer [D] (IJsselsteden) zendt aan een medewerker van RMC over deze aanbesteding:
- "Goedemiddag [vertrouwelijk],
Contact gehad met [vertrouwelijk] (NMa: de heer [A] van RMC) inzake het LL-vervoer Krimpen. Kan jij ons aangeven wat de 'zuidelijke en de noordelijke routes' zijn?
Met vriendelijke groet,
[D]
IJsselsteden Taxi Combinatie B.V." ⁵²
85. Op 8 maart 2010 vindt er tevens binnen RMC e-mailverkeer plaats, waaruit volgens de Raad blijkt dat de betrokken ondernemingen contact hebben gehad over deze aanbesteding. De heer [A] (RMC) schrijft hierin het volgende:

"Beste mensen,
Zojuist nog even gesproken met [C]. (IJsselsteden)

⁵⁰ Dossierstuk 16, met kenmerk 7130/16, pagina 12.

⁵¹ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41: bijlage 14.

⁵² Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41: bijlage 15.

(...)

Afgesproken met [vertrouwelijk] dat de RMC inschrijft op beide percelen. IJsselsteden wordt dan onderaannemer voor het noordelijk perceel en RMC rijdt zelf het zuidelijke perceel.

(...)”⁵³

86. De sluitingsdatum voor de inschrijving op de Aanbesteding LLV Krimpen aan den IJssel is 12 maart 2010. Zoals in de e-mailwisseling is besproken, heeft RMC op deze aanbesteding ingeschreven en IJsselsteden niet.⁵⁴ Op 7 april 2010 deelt de gemeente Krimpen aan den IJssel aan RMC mede dat de inschrijving van RMC als ongeldig wordt aangemerkt omdat zij geen geldige en actuele STO-verklaring⁵⁵ heeft overgelegd.
87. Ten aanzien van de aanbesteding Krimpen aan den IJssel stelt de Raad vast dat de betrokken ondernemingen onderling contact hadden. Zij geven in de e-mailwisseling van 8 maart 2010 aan dat Krimpen aan den IJssel tot het aanbestedingsgebied van IJsselsteden behoort en dat er daarom onderling overleg nodig is over deze aanbesteding. Op basis hiervan stelt de Raad vast dat de betrokken ondernemingen rekening houden met de gemaakte afspraken en het bestaan daarvan bevestigen.

(vii) Overige aanbestedingen

88. Uit het overzicht in Bijlage I blijkt dat bij de aanbestedingen Cliëntenvervoer Pameijer 2008, Zittend ziekenvervoer Achmea 2008, Dagbesteding Roteb 2009, Laurens dagbesteding 2009, Cliëntenvervoer ASVZ 2010, Dagbesteding Roteb 2010 en Laurens dagbesteding 2010 ofwel RMC, ofwel IJsselsteden (voor een bepaald perceel) inschreven. Dit is wat op grond van de afspraak verwacht mocht worden. De aanbesteding Leerlingenvervoer Spijkenisse vormt een uitzondering.

4.4 Zienswijze met betrekking tot de feiten en omstandigheden en de beoordeling door de Raad

89. RMC stelt dat het Rapport ten onrechte tot de conclusie komt dat RMC en IJsselsteden in de periode 2008 tot en met 2010 slechts op één aanbesteding beiden hebben ingeschreven. Zij stelt dat IJsselsteden en RMC ook beide op de aanbestedingen Leerlingenvervoer Hoeksche Waard en Leerlingenvervoer gemeente Spijkenisse hebben ingeschreven. Daarnaast gaat de NMa er volgens RMC aan voorbij dat RMC net als IJsselsteden bij de aanbesteding Achmea

⁵³ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130/41: bijlage 16.

⁵⁴ Dossierstuk 44, met kenmerk 7130/86: beantwoording vragenlijst gemeente Krimpen aan den IJssel over de Aanbesteding LLV Krimpen. [Vertrouwelijk] RMC en [vertrouwelijk] hebben ingeschreven op de Aanbesteding LLV Krimpen.

⁵⁵ Een STO verklaring is een verklaring van de Stichting voor informatie en ordening van de bedrijfstak besloten busvervoer, dat het desbetreffende bedrijf de CAO goed naleeft.

betrokken was via Transvision, omdat RMC daarin een [vertrouwelijk]% belang heeft. RMC geeft in haar zienswijze door middel van een tabel aan dat het inschrijfgedrag van RMC en IJsselsteden bij verschillende aanbestedingen, waaronder Spijkenisse en Schiedam, niet duidt op een verdeling van opdrachten.

90. De Raad is van oordeel dat voor zover RMC en IJsselsteden beide op aanbestedingen hebben ingeschreven of zelfs op elkaars "thuismarkt" hebben ingeschreven, dit geen afbreuk doet aan het bestaan en de werking van de Overeenkomst. De Raad wijst op de sterke aanwijzingen in de hierboven besproken gevallen voor het feit dat de betrokken ondernemingen zich in hun gedrag wel degelijk door de Overeenkomst lieten leiden, ook al hadden zij soms discussie over de uitvoering ervan. In het merendeel van de in Bijlage I opgenomen gevallen hebben RMC en IJsselsteden wel conform de Overeenkomst ingeschreven of anderszins conform de Overeenkomst gehandeld. Daarbij merkt de Raad op dat de Overeenkomst een situatie waarin zowel RMC als IJsselsteden inschrijft, of waarbij de partij wiens thuismarkt het betreft aan de ander toestemming verleent om in te schrijven, niet uitsluit. Ook het feit dat IJsselsteden, gezien de in het bestek gestelde geschiktheidseisen, niet altijd kon kwalificeren, doet niet af aan het bestaan en de werking van de Overeenkomst.
91. De derde alinea van punt 9 van de Overeenkomst breidt de daar genoemde verplichting uit tot de aan partijen gelieerde ondernemingen. Of partijen daarmee ook Transvision op het oog hebben gehad, welke onderneming een nogal bijzondere positie innam, valt niet uit het dossier op te maken. Transvision was van oorsprong een dochter van NS Reizigers. Ten tijde van de aanbesteding Zittend ziekenvervoer Achmea 2008 was RMC nog minderheidsaandeelhouder in Transvision met een aandeel van [vertrouwelijk]%; BDP Holding B.V. was de andere aandeelhouder met een aandeel van [vertrouwelijk]%. Aan het doen en laten van Transvision kan dus niet de conclusie worden verbonden dat RMC zich niet aan de Overeenkomst hield of trachtte te houden. Nadat RMC en de BIOS-groep [vertrouwelijk] aandeelhouder waren geworden, ging Transvision zich meer op activiteiten buiten de regio Rotterdam richten.
92. Voor zover de argumenten van RMC inzake de bovengenoemde aanbestedingen de juridische kwalificatie daarvan raken, gaat de Raad in het hoofdstuk Juridische beoordeling in op deze argumenten.

4.5 Einde van de samenwerking

93. Op 27 augustus 2010 zijn de namens IJsselsteden betrokken [REDACTED] (de heren [C] en [D]) bij uit functie getreden en heeft IJsselsteden Beheers Groep B.V. een 100%

aandeelhouder en een nieuwe directie gekregen, bestaande uit Taxi Govers B.V. Deze trof de Overeenkomst in de administratie niet aan en had ook geen contact meer met de [vertrouwelijk] van IJsselsteden. Van voortzetting van contacten met RMC is niet gebleken.

94. Taxi Govers B.V. heeft na 27 augustus 2010 de activiteiten van IJsselsteden voortgezet totdat zij met ingang van 5 oktober 2010 failliet is verklaard. IJsselsteden Beheers Groep B.V. is in staat van faillissement verklaard bij rechterlijke uitspraak van 9 november 2010. IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. is in staat van faillissement verklaard bij rechterlijke uitspraak van 30 november 2010. Als gevolg van deze faillissementen is IJsselsteden geheel van de markt verdwenen.
95. De Raad gaat ervan uit dat met de bovenbedoelde overname, onder de gegeven omstandigheden en gezien het verdere verloop van gebeurtenissen, de Samenwerkingsovereenkomst met RMC zonder betekenis is geworden en *de facto* is beëindigd.

4.6 Conclusie ten aanzien van de feiten en omstandigheden

96. Op grond van het bovenstaande stelt de Raad vast dat RMC en IJsselsteden op 18 december 2007 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Deze had enerzijds tot doel een aantal conflicten uit het verleden, waarbij ook derden (zoals RTC en BTR) betrokken waren, te beëindigen en de gevolgen van daarmee samenhangende beslissingen uit het verleden af te wikkelen. De Overeenkomst had anderzijds tot doel de toekomstige samenwerking gestalte te geven. In de punten 8 tot en met 11 van de Overeenkomst formuleren RMC en IJsselsteden jegens elkaar een aantal verplichtingen, die de onderlinge concurrentie bij het verwerven van opdrachten voor contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam effectief uitsluiten dan wel in hoge mate beperken.
97. De wilsovereenstemming omvat de afbakening van respectieve "thuismarkten", die RMC en IJsselsteden over en weer niet zullen betwisten. Daarbij worden verschillende specifieke situaties die zich bij aanbestedingen van contractueel taxivervoer kunnen voordoen, op sluitende wijze afgedekt. In het geval dat één van de partijen al houder is van een contract dat opnieuw wordt aanbesteed, zal de ander niet inschrijven. In het geval dat een derde houder is van een contract dat opnieuw wordt aanbesteed, treden partijen met elkaar in overleg over gezamenlijke dan wel afzonderlijke inschrijving. Actieve acquisitie met betrekking tot elkaars klanten of opdrachtgevers wordt eveneens uitgesloten. Aanvullend komen partijen overeen dat zij hun diensten niet zonder toestemming van de ander zullen aanbieden aan derden (op straffe van een boete) en dat bij onverhoopte verkrijging door een derde onderneming, zij daarmee desgevraagd alleen gezamenlijk in overleg zullen treden.

Daarnaast voorziet de overeenkomst in de mogelijkheid dat RMC en IJsselsteden in overleg over gezamenlijk inschrijven als dit de kans op succes vergroot en dat men elkaar zonodig als *most preferred partner* kan inschakelen.

98. De Raad stelt voorts vast dat RMC en IJsselsteden bij het merendeel van de aanbestedingen in de relevante periode de Overeenkomst met de boven omschreven elementen in acht hebben genomen, ofwel dat partijen in ieder geval rekening hielden met de gemaakte afspraken. Bij gecompliceerde situaties namen RMC en IJsselsteden contact met elkaar op over het te volgen inschrijfgedrag, zoals in vier gevallen in het dossier is gedocumenteerd. Dat RMC en IJsselsteden het niet altijd volledig met elkaar eens waren, en dat zij in enkele gevallen beide inschreven, doet naar het oordeel van de Raad geen afbreuk aan het bestaan de wilsovereenstemming met betrekking tot de opdrachtverdeling, noch aan de beoogde werking van de Overeenkomst.
99. Op 27 augustus 2010 komt *de facto* een einde aan de samenwerking tussen RMC en IJsselsteden.

5 JURIDISCHE BEOORDELING

5.1 Artikel 6 Mw

100. Artikel 6, eerste lid, Mw verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Blijkens de wetsgeschiedenis van de Mededingingswet sluit het kartelverbod van artikel 6 Mw zo veel mogelijk aan bij artikel 101, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit betekent dat de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof van Justitie)⁵⁶ voor de uitleg van artikel 6 Mw richtinggevend zijn.

⁵⁶ Vanaf 1 december 2009 maken het Hof van Justitie (het voormalige Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen) en het Gerecht (het voormalige Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen) deel uit van één rechterlijk stelsel onder de naam Hof van Justitie van de Europese Unie.

5.2 Overeenkomst

Beoordelingskader

101. Het verbod van artikel 6 Mw ziet zowel op overeenkomsten als op onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van een overeenkomst in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw wanneer de betrokken ondernemingen de gemeenschappelijke wil te kennen hebben gegeven zich op een bepaalde manier op de markt te gedragen.⁵⁷ Hiervan is onder meer sprake wanneer de ondernemingen het eens worden over een gezamenlijk plan dat hun individuele commerciële vrijheid beperkt of waarschijnlijk zal beperken, doordat wordt vastgesteld hoe zij zich op de markt jegens elkaar zullen gedragen of zich van een bepaald gedrag zullen onthouden. Alhoewel zulks gezamenlijke besluitvorming (en betrokkenheid bij een gemeenschappelijke regeling) impliceert, behoeft dit niet schriftelijk te worden vastgelegd. Het is niet noodzakelijk dat de ondernemingen van tevoren overeenstemming hebben bereikt over een allesomvattend gemeenschappelijk plan. Er zijn geen vormvereisten en contractuele sancties nodig en handhavingsmaatregelen zijn evenmin verplicht. Het bestaan van een overeenkomst kan derhalve uitdrukkelijk of impliciet blijken uit het gedrag van de ondernemingen.⁵⁸

Toepassing op de feiten en omstandigheden van deze zaak

102. De tussen RMC en IJsselsteden gesloten Samenwerkingsovereenkomst valt onder het begrip overeenkomst in de zin van artikel 6 Mw. De schriftelijke, op 18 december 2007 door de beide partijen ondertekende tekst laat daarover geen twijfel. Met zoveel woorden stellen RMC en IJsselsteden dat zij “*mede gelet op recente marktontwikkelingen de wens hebben om de huidige en de toekomstige samenwerking in een overeenkomst vast te leggen*” en dat zij “*...na ampele overweging, hebben geconcludeerd grote belangen toe te kennen aan een regionale samenwerking, waarvan de uitgangspunten en condities worden vastgelegd in de onderhavige samenwerkingsovereenkomst*”. De formulering van de verplichtingen over en weer met betrekking tot het toekomstig marktgedrag, in de punten 8 tot en met 11 van de Overeenkomst, is eenduidig en onvoorwaardelijk.
103. De jurisprudentie stelt niet als vereiste voor de toepasselijkheid van het kartelverbod dat er sprake is van een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst en het is evenmin een vereiste dat er sprake is van volledige wilsovereenstemming. Zoals hierboven bij randnummers 39 e.v. is beschreven, kwam de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst tot stand op basis van een concepttekst die op 17 en 18 december 2007 in contacten over en weer nog is gecorrigeerd en aangevuld. In hoeverre op 17 december 2007 al gesproken kan

⁵⁷ Zie o.m. GvEA EG 20 april 1999, nr. T-305/94 e.a., *Jur.* 1999, p. II-931 (*Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e.a./Commissie*), r.o. 715.

⁵⁸ Zie o.a. Beschikking van de Commissie van 23 april 1986 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag, (*PBL* 230). Dit is later bevestigd in GvEA EG 17 december 1991, nr. T-7/89, *Jur.* 1991, p. II-01711 (*SA Hercules Chemicals NV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen*), r.o. 262-264.

worden van een *materiële* wilsovereenstemming met betrekking tot de verdeling van werkgebieden tussen RMC en IJsselsteden welke onder artikel 6 Mw valt, laat de Raad in het midden. Bij deze afwijking van het Rapport overweegt de Raad dat het slechts om een enkele dag verschil gaat, dat er zich in de tussentijd geen gelegenheid voordeed de afspraak in praktijk te brengen en dat *in casu* ook anderszins aan het tijdsverloop geen consequenties waren verbonden.

104. Uit de analyse in paragraaf 4.3 van aanbestedingen uit de jaren 2008-2010 blijkt dat RMC en IJsselsteden zich in hun gedrag van de Overeenkomst bewust waren, hiermee rekening hielden en elkaar daarop aanspraken.

Conclusie

105. De Samenwerkingsovereenkomst tussen RMC en IJsselsteden van 18 december 2007 is een overeenkomst in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw.

5.3 Mededingingsbeperking

Beoordelingskader

106. Het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw is van toepassing op een overeenkomst wanneer zij ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
107. Van een mededingingsbeperkende strekking is reeds sprake wanneer de overeenkomst negatieve gevolgen voor de mededinging kan hebben. Met andere woorden, het volstaat dat zij concreet, gelet op de juridische en economische context ervan, geschikt is om te leiden tot verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging.⁵⁹ Niet is vereist dat de overeenkomst de belangen van concurrenten of consumenten schaadt; de mededingingsregels dienen volgens vaste rechtspraak ertoe om de structuur van de markt en daarmee de mededinging als zodanig veilig te stellen.⁶⁰ De vraag of en in welke mate een dergelijk gevolg daadwerkelijk intreedt, kan slechts relevant zijn voor de berekening van het bedrag van de boete.⁶¹
108. Of sprake is van een mededingingsbeperkende strekking dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval. Met betrekking tot de vraag of een overeenkomst ertoe strekt de mededinging te beperken, zijn met name relevant de objectieve doelstellingen die zij nastreeft en de economische en juridische context ervan.

⁵⁹ CBb 12 augustus 2010, zaak AWB 06/657, 06/660 en 06/661, *T-Mobile Netherlands B.V. e.a.*, pt. 7.3.2.

⁶⁰ HvJ EG 6 oktober 2009, nrs. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P en C-519/06 P, *Jur.* 2009, p. I-9291, (*GlaxoSmithKline Services e.a.*), pt. 63.

⁶¹ HvJ EG 4 juni 2009, nr. C-8/08, *Jur.* 2009, p. I-04529, (*T-Mobile Netherlands B.V. e.a.*), pt. 31.

Het oogmerk of de bedoeling van de betrokken ondernemingen is geen noodzakelijk element om te bepalen of een overeenkomst een mededingingsbeperkende strekking heeft.⁶²

109. Als eenmaal is vastgesteld dat de overeenkomst ertoe strekt de mededinging te beperken, verhinderen of vervalsen, behoeven voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, Mw de concrete gevolgen van een overeenkomst niet nader te worden onderzocht.⁶³ Overeenkomsten vallen zelfs dan onder artikel 6, eerste lid, Mw wanneer mededingingsbeperkende gevolgen op de markt ontbreken.⁶⁴

Toepassing op de feiten en omstandigheden van deze zaak

110. In het onderhavige geval acht de Raad de punten 8 tot en met 11 van de Overeenkomst (aangehaald bij randnummer 49 en geduid bij randnummers 50-52), gelet op de juridische en economische context, concreet geschikt om te leiden tot verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging bij aanbestedingen van contractueel taxivervoer.
111. De Raad stelt voorop dat RMC en IJsselsteden in de relevante periode beide actief waren in de regio Rotterdam en aldaar beide relatief eenvoudig elke vorm van contractueel taxivervoer konden aanbieden. Tot december 2007 was IJsselsteden aangesloten bij RTC die voor RMC opdrachten uitvoerde die aan RMC waren gegund. Derhalve waren zij directe concurrenten van elkaar bij aanbestedingen van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam.
112. Kern van de afspraak was dat RMC en IJsselsteden zich ertoe verbonden elkaar geen concurrentie aan te doen op hun wederzijdse thuismarkten, die in de Overeenkomst zodanig worden omschreven dat geen sprake is van overlapping. In het geval dat één van de partijen al houder is van een contract dat opnieuw wordt aanbesteed, zal de ander op die aanbesteding niet inschrijven. Naar het oordeel van de Raad lag in deze bepalingen op zichzelf gezien reeds een beperking dan wel vervalsing van de mededinging besloten. Door af te spreken elkaar op voornoemde wijze geen concurrentie aan te doen, beperkten RMC en IJsselsteden het aantal concurrerende inschrijvingen op de desbetreffende aanbestedingen. Zij onthielden bij voorbaat de aanbestedende dienst een gegadigde, zodat deze dienst een verkeerd beeld kreeg van de daadwerkelijke concurrentie in en interesse voor de aanbesteding. Met de bepaling in punt 11 van de Overeenkomst dat RMC en IJsselsteden ook niet op eigen initiatief elkaars klanten of opdrachtgevers mochten benaderen, werden de

⁶² HvJ EG 4 juni 2009, nr. C-8/08, *Jur.* 2009, p. I-04529, (*T-Mobile Netherlands B.V. e.a.*), pt. 24 en 27.

⁶³ Zie o.m. HvJ EG 20 november 2008, nr. C-209/07, *Jur.* 2008, p. I-08637, (*Beef Industry Development Society*), pt. 16; HvJ EG 21 september 2006, zaak C-105/04 P, *Jur.* 2006, p. I-8725 (*Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissie*), pt. 125; HvJ EG 13 juli 1966, nr. 56/64 en 58/64, *Jur.* 1978, p. 131 (*Consten-Grundig*), pt. 7; en HvJ EG 6 oktober 2009, nrs. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P en C-519/06 P, *Jur.* 2009, p. I-9291, (*GlaxoSmithKline Services e.a.*), pt. 55.

⁶⁴ HvJ EG 8 juli 1999, nr. C-49/92 P, *Jur.* 1999, p. I-4125, (*Anic Partecipazioni*), pt. 122.

mogelijkheden voor aanbestedende diensten in om een goed beeld te krijgen van het aanbod in de regio verder verkleind.

113. Door overeen te komen dat, indien één van de partijen al houder was van een contract dat opnieuw wordt aanbesteed, de ander haar diensten niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de zittende partij aan derden zou aanbieden (op straffe van een boete), werden voorts de mogelijkheden van derden verkleind om concurrerende aanbiedingen te doen en tot kansrijke inschrijvingen te komen. Dat dit ook in de praktijk van belang was, volgt uit de bevinding in hoofdstuk 3 van het onderhavige besluit, dat in geval van contractueel taxivervoer onderaanneming een veel gebruikt middel is om contracten te kunnen uitvoeren, met name om buiten het traditionele eigen werkterrein actief te worden. Derden werden aldus belemmerd in hun mogelijkheden om met gebruikmaking van onderaannemers als hoofdaannemer hun diensten te verlenen/aanbieden in genoemde thuismarkten van IJsselsteden en RMC en daarmee in de regio Rotterdam. Ook op deze wijze was de Overeenkomst geschikt om het aantal concurrerende inschrijvingen op de desbetreffende aanbestedingen in het nadeel van de opdrachtgever te beperken, dan wel de concurrentiedruk van derde partijen bij die aanbestedingen te verminderen.
114. De bepaling inhoudende dat wanneer de houder van een contract de uitvoering van het complete contract dat opnieuw werd aanbesteed, niet aankon of aan wilde, zij de ander als *most preferred partner* diende in te schakelen, beschouwt de Raad op zichzelf gezien niet als een bepaling die ten doel heeft de mededinging te beperken. In het geheel der bepalingen van de Overeenkomst kan zij evenwel derden nog op een andere manier hinderen om voet aan de grond te krijgen in de regio Rotterdam, namelijk als onderaannemer van RMC of IJsselsteden.
115. Uit het voorgaande volgt dat de Overeenkomst objectief gericht was op het behouden van bestaande posities van RMC en IJsselsteden in hun thuismarkten binnen de regio Rotterdam. RMC en IJsselsteden ondervonden geen hinder van onderlinge concurrentie en minder hinder van de concurrentie van derden. Mocht het scenario zich echter voordoen dat een derde toch de aanbesteding won en het contract dat oorspronkelijk van RMC of IJsselsteden was, gegund kreeg, dan bepaalde de Overeenkomst dat IJsselsteden en RMC in gezamenlijk overleg traden met de nieuwe contracthouder over de condities waaronder desgevraagd diensten aangeboden werden aan de nieuwe contracthouder. Hiermee spraken IJsselsteden en RMC in essentie af om elkaar ook in die situatie geen concurrentie aan te doen, dit in het nadeel van de nieuwe contracthouder. De Raad roept hierbij wederom in herinnering dat onderaanneming een veel gebruikt instrument is bij contractueel taxivervoer en wijst erop dat er normaliter juist over de bedoelde "condities", waaronder tarieven, onzekerheid dient te bestaan tussen concurrenten. De Overeenkomst heeft ook op dit punt een mededingingsbeperkend karakter.

116. Naast het behouden van bestaande posities van RMC en IJsselsteden in de regio Rotterdam, was de Overeenkomst ook gericht op het uitbreiden van posities van RMC en IJsselsteden in hun thuismarkten. Mocht in één van die thuismarkten namelijk een contract van een derde opnieuw worden aanbesteed, dan bepaalde de Overeenkomst dat IJsselsteden en RMC in overleg traden. Dit overleg kon als uitkomst hebben dat een gezamenlijke inschrijving volgde, dan wel dat beiden partijen hun eigen weg gingen en beide afzonderlijk inschreven. Hoewel de bepaling in punt 10 van de Overeenkomst op zichzelf tamelijk sober en neutraal is geformuleerd, bergt zij gezien de algehele hechte samenwerking die partijen nastreven het gevaar in zich dat ook hierdoor de mededinging wordt beperkt. Normaal gesproken moeten concurrenten immers in onzekerheid verkeren over elkaars interesse in aanbestedingen en over de strategie die ieder van hen van plan is te volgen met betrekking tot deze aanbestedingen. Door voor deze situatie af te spreken vooraf met elkaar te overleggen, wordt deze onzekerheid tussen RMC en IJsselsteden ten minste voor een deel weggenomen. Het is inherent aan een dergelijke bespreking voorafgaande aan een aanbesteding, waarbij ieders kansen worden gewogen en afgezet tegen de mogelijkheid van een gezamenlijke inschrijving, dat concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld. RMC en IJsselsteden hebben althans geen voorzorgen genomen om dit te voorkomen.
117. De Raad concludeert op grond van het voorgaande dat de Overeenkomst concreet geschikt was om de mededinging te beperken dan wel te vervalsen bij aanbestedingen van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam. De overeenkomst hield een structureel vormgegeven samenwerking en overlegstructuur tussen de betrokken ondernemingen in en bevatte een samenstel aan bepalingen, gericht op het behouden en versterken van bestaande contracten en posities op de wederzijdse thuismarkten. De verschillende elementen daarvan droegen bij aan het objectieve doel de onderlinge concurrentie tussen RMC en IJsselsteden uit te schakelen en de concurrentie van derden te verzwakken. Het kernelement, bestaande uit een onderlinge territoriale verdeling van opdrachten wordt sinds jaar en dag beschouwd als naar zijn aard mededingingsverstrend.⁶⁵
118. Daarbij neemt de Raad het feitelijk gedrag op de markt in ogenschouw: de Overeenkomst is geen dode letter gebleken. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat RMC en IJsselsteden in voorkomende gevallen conform de Overeenkomst in overleg zijn getreden en met de gemaakte afspraken rekening hebben gehouden.
119. Hoewel het oogmerk of de subjectieve intentie van de betrokken ondernemingen niet van doorslaggevend belang is voor de vraag of sprake is van een mededingingsbeperkende strekking, ziet de Raad in de subjectieve intenties van betrokken ondernemingen wel een

⁶⁵ Vgl. artikel 101, eerste lid, sub c VWEU en de Mededeling van de Commissie van 6 januari 2001, Pb. 2001, C3, p.2. nummer 25.

bevestiging dat de Overeenkomst een mededingingsbeperkende strekking heeft. De Raad wijst in dit verband op de onderstaande verklaringen van de heer [C] en de heer [D] (beiden van IJsselsteden) en een notitie van de heer [A] (RMC). Uit deze verklaringen en de notitie volgt dat de betrokken ondernemingen beoogden de natuurlijke marktwerking door middel van de Overeenkomst te beïnvloeden (Onderstrepings NMa).

"Het doel voor ons als onderneming is geweest dat wij ons bedrijf zouden beschermen tegen RMC. Als u kijkt naar de overeenkomst ziet u dat RMC niet meer in ons gebied mocht inschrijven op aanbestedingen waardoor ons gebied beschermd werd tegen één van onze belangrijkste concurrenten (..) De overeenkomst is een product van de wensen van beide ondernemingen." ⁶⁶

"U houdt mij voor dat in de samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt worden voor de toekomst, dus dat als er een aanbesteding van bijvoorbeeld leerlingenvervoer in Capelle aan den IJssel is, dat IJsselsteden dan inschrijft en RMC niet. Uw conclusie is correct. Ik kan wel om de hete brei heen draaien maar het is gewoon zo. De reden is om de continuïteit van ons bedrijf zeker te stellen. We maken gebruik van elkaars capaciteiten om een derde taxionderneming buiten de deur te houden." ⁶⁷

"U vraagt mij naar het onderwerp aanbesteding VOM waaraan gerefereerd wordt. Ik denk dat de afspraak tot onderaannemerschap in deze overeenkomst geregeld is. RMC was bang gezien onze expansiedrift, dat IJsselsteden zelfstandig Vervoer op Maat in Rotterdam zou gaan inschrijven. Wij konden helemaal niet alleen inschrijven, want we hadden hun al nodig voor WMO in Capelle. Misschien waren ze bang dat wij samen met Connexxion zouden inschrijven, want dat hadden wij wel kunnen doen. Toen zijn we overeengekomen dat we als onderaannemer van RMC op Vervoer op Maat zouden inschrijven."

"IJsselsteden heeft als onderaannemer van RMC op Vervoer op Maat van Rotterdam ingeschreven. Dat was eigenlijk een soort uitruil voor ons. RMC was bang dat wij zelfstandig of als onderaannemer van bijvoorbeeld Connexxion zouden inschrijven voor Vervoer op Maat van Rotterdam. Wij, Ron en ik, hebben deze angst van RMC uitgenut. Uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst was dat Vervoer op Maat in Rotterdam viel onder de thuismarkt van RMC. RMC mocht daarmee volgens de samenwerkingsovereenkomst inschrijven op Vervoer op Maat in Rotterdam en wij, IJsselsteden, mochten dat volgens de samenwerkingsovereenkomst niet. Daarvoor kregen wij dan eigenlijk het onderaannemerschap in Vervoer op Maat in Rotterdam". ⁶⁸

⁶⁶ Dossierstuk 17, met kenmerk 7130/24, verklaring de heer [C], pagina 6.

⁶⁷ Dossierstuk 16, met kenmerk 7130/16, verklaring de heer [D], pagina 7.

⁶⁸ Dossierstuk 60, met kenmerk 7130/42, bijlage 3, pagina 2.

*"De RMC heeft een samenwerking overeenkomst gesloten met IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. Een kopie van de overeenkomst is aan de agenda stukken toegevoegd. Zoals uit deze stukken blijkt doen de RMC en IJsselsteden al op een aantal terreinen met elkaar zaken en was het gezien de komende aanbesteding Vervoer op Maat verstandig om de goede relatie te behouden en geen nieuwe concurrent te kweken."*⁶⁹

*"Zoals jullie weten heb ik er alles aan gedaan om te voorkomen dat Connexxion in Rotterdam een partner zou vinden waar men bij de inschrijving zaken mee kon doen en derhalve heb ik vooraf met de 2 belangrijkste partijen samenwerkingsovereenkomsten gesloten die zoals nu is gebleken beide goed hebben gewerkt."*⁷⁰

120. De Raad ziet in deze citaten de bevestiging van het defensieve karakter van de afspraak. De samenwerking tussen RMC en IJsselsteden had niet het karakter van een strategische alliantie in de goede zin van het woord. Zij was niet primair gericht op een bundeling van krachten en synergie, opdat men samen, maar in concurrentie met anderen tot betere aanbiedingen zou kunnen komen. Zij was daarentegen gericht op het afweren van concurrentie die de betrokken ondernemingen tot het leveren van betere prestaties zou hebben aangespoord.
121. De Raad voegt aan het bovenstaande nog toe dat, ook al doet zich in het onderhavige geval geen afstemming van prijzen of andere elementen van de inhoud van offertes voor, de afspraak dat slechts één van de twee partijen zal meedingen evengoed een element van misleiding van opdrachtgevers bevat. Aan opdrachtgevers wordt de mogelijkheid onthouden zich een juist beeld te vormen van het voorhanden aanbod en aanbieders met elkaar te vergelijken. Dit vormt een belangrijk onderscheid met (de gevolgen van) concentraties op dezelfde markt: deze vinden immers plaats in alle openheid en dat biedt zowel de opdrachtgevers als de andere ondernemingen op de markt de mogelijkheid met het bestaan van de nieuwe, mogelijk sterkere gefuseerde entiteit rekening te houden. Andere ondernemingen zullen daardoor zelfs kunnen worden aangezet tot een felle concurrentie.

Zienswijze RMC en beoordeling door de Raad

122. RMC stelt dat er diverse omstandigheden zijn die voor de totstandkoming van de overeenkomst van belang zijn. RMC legt onder andere uit dat IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. lid was van RTC en derhalve gebonden was aan de Algemene Voorwaarden die voor RTC golden. Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden waren een relatiebeding en een non-concurrentiebeding. IJsselsteden was al op basis van haar lidmaatschap bij RTC aan dit relatie- en een non-concurrentiebeding gebonden. Dit hield volgens RMC in dat IJsselsteden

⁶⁹ Dossierstuk 60, met kenmerk 7130/42, bijlage 3, pagina 2.

⁷⁰ Dossierstuk 60, met kenmerk 7130/42, bijlage 4.

los van RTC geen klantenkring op mocht bouwen. RMC acht deze feiten van belang, omdat RMC er van wordt beschuldigd met IJsselsteden een opdrachtverdeling te hebben afgesproken.

123. RMC betoogt voorts dat het karakter van het samenwerkingsverband RTC meebrengt dat er problemen kunnen ontstaan wanneer de grotere leden van RTC zowel in de hoedanigheid van onderaannemer als in de hoedanigheid van zelfstandige inschrijven. Zij legt uit dat IJsselsteden tot 1 april 2007 aangesloten is geweest bij RTC. Doordat Transvision (en daarmee RMC) in 2007 het Valys-contract kwijtraakte aan Connexxion, verloren RMC en andere RTC ondernemers een groot deel van hun omzet. Er ontstond een conflict binnen RTC toen bleek dat Connexxion een deel van haar Valys-vervoer door IJsselsteden liet rijden. Immers, IJsselsteden was gebonden aan een non-concurrentiebeding en een relatiebeding. RMC stelt dat het soms moeilijk is voor RTC om deze bedingen te handhaven, terwijl leden van RTC dat wel van RTC en in zekere zin ook van RMC verwachten. Mede om die reden heeft RMC het aan RTC-leden doen voorkomen alsof RMC had geprobeerd IJsselsteden te belemmeren om in te schrijven op de Valys-aanbesteding. Om de RTC leden gerust te stellen, zijn de bepalingen in punten 9 en 10 van de Overeenkomst opgenomen. In werkelijkheid wisten zowel IJsselsteden als RMC dat deze bepaling geen opdrachtverdeling tot doel of effect had, maar het bewaren van de rust binnen de RTC gelederen tot doel had. Ter ondersteuning van haar zienswijze heeft RMC een door de heren [C] en [D] opgestelde verklaring met betrekking tot de samenwerking tussen RMC en IJsselsteden aan haar zienswijze toegevoegd.
124. RMC stelt voorts dat de hiervoor beschreven situatie voor haar gecompliceerd was, omdat zij met - onder andere - IJsselsteden de Capelse Vervoer Groep heeft opgericht voor exploitatie voor het WMO-vervoer in Capelle aan den IJssel. Medio december 2007 wordt RMC benaderd door de gemeente Capelle aan den IJssel om het contract voor leerlingenvervoer in die gemeente over te nemen vanwege het faillissement van de Capelse Taxi Centrale, een 100% dochteronderneming van IJsselsteden. IJsselsteden reed dat vervoer al voor de Capelse Taxi Centrale en werd door RMC benaderd om dit vervoer te blijven rijden. Om RTC tegemoet te komen, stelt RMC voor dat IJsselsteden, wanneer zij voor de Valys-aanbesteding ondernemers van RTC nodig heeft, dit via de meldkamer van RMC zal laten verlopen en dat IJsselsteden in ruil daarvoor werk krijgt in het VOM project, mits RMC deze aanbesteding wederom gegund zal krijgen.
125. RMC stelt ten slotte dat de Overeenkomst in alle haast is opgesteld omdat naar aanleiding van bovenstaande omstandigheden snel gehandeld moest worden. Zij stelt voorts dat de Overeenkomst alleen werd opgesteld om de verhoudingen tussen RMC en IJsselsteden vast te leggen in het kader van het uitvoeren van het contract met de Gemeente Capelle en om de ruil met betrekking tot de Valys- en VOM 2008-ritten vast te leggen. Met dit pakket aan

afspraken hoopten RMC en IJsselsteden de gevoeligheden bij RTC het hoofd te kunnen bieden.

126. De Raad ziet de door RMC geschetste beweegredenen weerspiegeld in een deel van de Overeenkomst, met name de punten 4 tot en met 7 en 12 tot en met 14 en hierin kan ook de directe aanleiding gelegen zijn waarom partijen elkaar opzochten. Echter, de Overeenkomst als geheel ging verder dan was vereist voor het doel de gemoederen binnen de gelederen van RTC te kalmeren. De punten 8 tot en met 11 houden naar het oordeel van de Raad geen verband met gevoeligheden bij RTC, met de overgangssituatie in Capelle of met een ruil van Valys- en VOM-opdrachten. Zij bevatten wel, zoals boven geconcludeerd, objectieve beperkingen van de mededinging. De Raad ziet dit ondersteund door de bij randnummer 119 aangehaalde verklaringen met betrekking tot de intentie van de betrokken ondernemingen. Daarbij is de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.
127. Dat de betrokken ondernemingen met een deel van de Overeenkomst mede het oplossen van conflicten of fricties als gevolg van ontvlechting van voormalige samenwerkingsverbanden en gewijzigde marktverhoudingen voor ogen hadden, staat niet in de weg aan de conclusie dat de Overeenkomst voor een ander deel mededingingsbeperkend van aard was. Dit betoog kan RMC dan ook niet baten.⁷¹
128. Daarbij merkt de Raad op dat de onderhavige overeenkomst is gesloten tussen RMC en IJsselsteden en niet tussen RTC en IJsselsteden. RMC en IJsselsteden zijn twee zelfstandige ondernemingen. Dat RMC voor 49% in handen was van RTC, maakt dit niet anders. Dat de restrictieve bepalingen in de Overeenkomst reeds geheel besloten zouden liggen in het non-concurrentiebeding van RTC, wat daarvan verder ook zij, roept de vraag op waarom deze dan nog eens zijn vastgelegd en waarom, nu zij toch zijn vastgelegd, een verwijzing daarnaar in "status informatie" die de Overeenkomst in ogenschouw neemt, ontbreekt.
129. De Raad is van oordeel dat het feit dat de Overeenkomst zoveel verder ging in het beperken van de concurrentie niet te wijten kan zijn aan slordige formuleringen door de haast waarmee de Overeenkomst tot stand kwam. Er is in e-mails over en weer uitdrukkelijk over de tekst gecorrespondeerd. De bewoordingen van de Overeenkomst maken een weloverwogen indruk en laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De vastlegging moest immers "een stevig fundament onder de samenwerking" leggen (aldus punt 9 vierde alinea).
130. RMC stelt dat de wijze van inschrijven bij een aantal aanbestedingen juist laat zien dat er geen sprake was van een afspraak om onderling opdrachten te verdelen of van een marktverdeling of van een mededingingsbeperkende afspraak. Er zou juist in strijd met de

⁷¹ Zie HvJ EG, 8 november 1983, *IAZ/Commissie*, gev. zaken 96-102 e.a., Jur. 1983, p. 3411.

inhoud van de Overeenkomst zijn ingeschreven. RMC verwijst hiervoor onder andere naar de aanbesteding leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel, waarbij geen contact heeft plaatsgevonden tussen RMC en IJsselsteden en waarbij zowel RMC als IJsselsteden hebben ingeschreven en op de aanbesteding leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel waarbij RMC juist wel inschrijft op deze aanbesteding. Voorts merkt RMC op dat zij, gezien de indeling van deze aanbesteding, wel contact met IJsselsteden moest hebben over onderaanneming. Het benaderen van een onderaannemer is volgens RMC niet verboden op grond van artikel 6, eerste lid, Mw. Er is volgens RMC geen enkel bewijs dat het overleg tussen de bestuurders over deze aanbesteding, zag op een marktverdeling. Voorts noemt RMC nog de aanbesteding VOM 2008. Ten aanzien van deze aanbesteding stelt RMC dat er geen mededingingsbeperkende afspraken zijn gemaakt tussen RMC en IJsselsteden omdat IJsselsteden niet zelfstandig kwalificeerde voor dit contract. Een afspraak tussen RMC en IJsselsteden op grond waarvan IJsselsteden niet mocht inschrijven kan derhalve geen effect hebben op de mededinging.

131. De Raad heeft de door RMC genoemde specifieke aanbestedingen besproken bij randnummers 57-61 (LLV Capelle aan den IJssel), 82-87 (LLV Krimpen aan den IJssel) en 73-80 (VOM 2008). Het bleek in die gevallen te gaan om complicaties, soms voortvloeiende uit onenigheid tussen partijen over wie voor welke ritten als "rechthebbende" had te gelden, soms voortvloeiend uit de bijzondere omstandigheden van de betreffende aanbesteding, waardoor ogenschijnlijk een andere handelwijze werd gevolgd dan in eerste instantie was voorzien. Het bleek echter dat partijen er steeds naar streefden in onderling overleg tot oplossingen te komen in de geest van de Overeenkomst, waarvan zij de gelding klaarblijkelijk geen van beide ooit in twijfel trokken. De Raad merkt op dat de conclusie dat sprake is van een mededingingsbeperkende overeenkomst in de zin van artikel 6 Mw gebaseerd is op de op 18 december 2007 tussen RMC en IJsselsteden tot stand gekomen wilsovereenstemming om zich op de markt op een bepaalde wijze te gedragen en niet op de onderlinge contacten die nadien bij individuele aanbestedingen hebben plaatsgevonden of op de wijze van inschrijven van RMC en IJsselsteden.

Conclusie

132. De Raad concludeert dat de afspraken zoals die zijn neergelegd in de Overeenkomst in de gegeven economische en juridische context tot doel hadden de mededinging te beperken dan wel te vervalsen bij aanbestedingen van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam. De betrokken ondernemingen hebben zich doorgaans conform deze afspraak (trachten te) gedragen.

5.4 Merkbaarheid

Beoordelingskader

133. Zoals hiervoor weergegeven, behoeven voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, Mw de concrete gevolgen van de overeenkomst niet nader te worden onderzocht wanneer, zoals in de onderhavige zaak, is vastgesteld dat de overeenkomst ertoe strekt de mededinging te verhinderen, beperken of vervalsen. Een dergelijke overeenkomst ontkomt slechts aan het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw wanneer zij, vanwege de zwakke positie van partijen op de relevante markt, de mededinging op de markt slechts in zeer geringe mate kan beïnvloeden.⁷² Hierbij moet ook in aanmerking worden genomen of het bij de overeenkomst betrokken deel van de relevante markt van zodanig geringe omvang is, dat uitgesloten moet worden geacht dat hiervan betekenisvolle invloed uitgaat op de uitkomsten van de markt.⁷³
134. Naar het oordeel van de Raad volgt uit de Europese en Nederlandse jurisprudentie op dit vlak dat het bij de voorgaande toets draait om de marktmacht die de betrokken ondernemingen hebben. Als de betrokken ondernemingen gezamenlijk evident geen marktmacht hebben, zal een overeenkomst in de regel niet merkbaar de mededinging kunnen beperken.⁷⁴ Als de betrokken ondernemingen daarentegen gezamenlijk een hoog marktaandeel hebben, is in beginsel aannemelijk dat zij meer dan geringe marktmacht hebben, en is voldaan aan het merkbaarheidsvereiste.⁷⁵

Toepassing op de feiten en omstandigheden van deze zaak

135. De Raad is van oordeel dat de betrokken ondernemingen niet een zodanig zwakke positie innemen dat de mededinging in de regio Rotterdam slechts in zeer geringe mate kan worden beïnvloed en overweegt daartoe het volgende.
136. Hoewel RMC daarbij enkele kanttekeningen heeft geplaatst, hebben RMC en IJsselsteden niet wezenlijk bestreden dat zij alle vormen van contractueel taxivervoer konden aanbieden, zoals in het Rapport gesteld. Daarbij hebben zij de Overeenkomst zodanig ruim geformuleerd, dat deze ook zag op alle mogelijke vormen van contractueel taxivervoer, zodat het maken van een nader onderscheid wat de betrokken productmarkt betreft reeds om die reden niet nodig is.⁷⁶

⁷² Zie CBb 12 augustus 2010, AB 2010, 342 (*T-Mobile e.a./NMa*); CBb 7 december 2005, LJN: AU8309, (*Secon en G-Star/Basilicum en Chilly*).

⁷³ CBb 12 augustus 2010, AB 2010, 342 (*T-Mobile e.a./NMa*).

⁷⁴ HvJ 9 juli 1969, nr. 5/69, *Jur.* 1969, p. 295 (*Völck/Vervaecke*); CBb 7 december 2005, LJN: AU8309, (*Secon en G-Star/Basilicum en Chilly*).

⁷⁵ GvEA EG 12 september 2007, nr. T-30/05, *Jur.* 2007, p. II-00107 (*Prym*), r.o. 102-105 (onbestreden in hoger beroep, zie HvJ EU 30 april 2009, nr. C-534/07, *Jur.* 2009, p. I-07415); Rb. Rotterdam 13 juli 2006, LJN: AY4035, AM 2006, nr. 9 (onbestreden in hoger beroep, zie CBb 12 augustus 2010, AB 2010, 342 (*T-Mobile e.a./NMa*); CBb 4 oktober 2011, LJN: BT6521 (*Giant Europe e.a./NMa*), r.o. 4.7.7.3. In HvJ EG 1 februari 1978, nr. 19/77, *Jur.* 1978, p. 00131 (*Miller*) was reeds geen nadere motivering van de merkbaarheid van de overeenkomst nodig, nu Miller International over een marktaandeel van meer dan 20% beschikte.

⁷⁶ CBb 4 oktober 2011, LJN: BT6521 (*Giant Europe e.a./NMa*), r.o. par. 4.5.3.

137. Met de omschrijving van hun “thuismarkten” hebben de betrokken ondernemingen tevens de werkingssfeer van de Overeenkomst aangegeven. IJsselsteden was typisch een lokale speler met, zoals uit de citaten bij randnummer 119 blijkt, een zekere “expansiedrift”, maar de beoogde expansie ging vooralsnog niet de regio Rotterdam te buiten. RMC laat de aan haar gegunde aanbestedingen uitvoeren door taxiondernemingen die zijn aangesloten bij RTC, hetgeen betekent dat RMC voor het aanbieden van contractueel taxivervoer (tot op zekere hoogte) gebonden is aan de regio Rotterdam. Beide spelers zijn dus elkaars directe, nabije concurrenten in de Rotterdamse arena.
138. Uit het onderzoek vermeld bij randnummer 35 en 36 blijkt dat aan aanbestedingen van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam in de relevante periode naast RMC en IJsselsteden slechts een beperkt aantal andere inschrijvers deelneemt; zie ook het overzicht in Bijlage I. RMC en IJsselsteden behoren tot de zeven belangrijkste ondernemingen die actief waren in de regio. Het ging daarbij om aanbestedingen waaraan hooguit vijf en meestal minder inschrijvers deelnamen en waarbij de betrokken ondernemingen tot de gerede kanshebbers gerekend moeten worden. Dat laatste blijkt niet alleen uit de getalsmatige verhoudingen, maar ook uit hun goede *track record* over een langere periode: bij 10 van de 24 van de onderzochte aanbestedingen heeft een van hen gegund gekregen, indien zij meedongen kregen zij in 2 van de 3 gevallen de opdracht.⁷⁷
139. RMC en IJsselsteden moeten geacht worden zelf een redelijke inschatting van hun kansen te kunnen maken; wie hun concurrenten waren, was bekend, ook als het landelijke spelers betrof, zoals Connexxion of de BIOS-groep.
140. Onder de gegeven omstandigheden acht de Raad het aannemelijk dat het uitschakelen van de onderlinge concurrentie de mededinging in de regio Rotterdam bij de aanbestedingen in de relevante periode merkbaar heeft kunnen beïnvloeden.
141. De rechtbank Rotterdam heeft in de uitspraak in de zaak Dakdekkers,⁷⁸ die na uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven onherroepelijk is geworden⁷⁹ alsook in de uitspraak in de zaak Boomkwekerijen⁸⁰ vastgesteld dat in geval van mededingingsbeperkende afspraken voorafgaande aan een aanbesteding, de relevante markt beperkt is tot de aanbieders bij de betreffende aanbesteding. Indien op grond hiervan de situatie per afzonderlijke aanbesteding in aanmerking wordt genomen, is gelet op de verhoudingen als

⁷⁷ Bij een aanbesteding, VOM 2008, voldeed IJsselsteden niet aan de besteisen, maar kon zij haar diensten aanbieden aan een derde. RMC kon er op rekenen dat, conform de Overeenkomst, IJsselsteden haar diensten niet aan zou bieden aan Connexxion, de grootste concurrent van RMC.

⁷⁸ Rb. Rotterdam 24 juli 2007, LJN: BB0750, (*Erdo B.V. vs NMa*).

⁷⁹ CBb 8 april 2010, LJN: BM1588, (*Erdo B.V. vs NMa*).

⁸⁰ Rb. Rotterdam 1 juli 2010, LJN: BM9911, (*Darthuizer Boomkwekerijen B.V., Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen B.V. en Van den Oever Holding B.V. vs NMa*).

weergegeven in Bijlage I in alle gevallen eveneens sprake van een merkbare invloed van de afspraak.

Zienswijze RMC en beoordeling door de Raad

142. RMC betwist de stelling dat RMC en IJsselsteden een aanzienlijk aandeel hebben bij de aanbestedingen in de regio Rotterdam, of in ieder geval is dat niet het geval voor IJsselsteden. In verhouding tot de marktpositie van Connexxion op het gebied van contractueel taxivervoer in heel Nederland stelt RMC dat zij geen aanzienlijk deel heeft bij aanbestedingen in de regio Rotterdam, althans dat zij niet beschikt over een sterke marktpositie. Voor het vaststellen van een marktpositie is een analyse van aanbestedingsgedrag vereist, zoals de Raad in zijn besluit van zaak 6957/Veolia-CDC-Transdev⁸¹ heeft gedaan, waarbij ook andere factoren worden betrokken.
143. RMC merkt vervolgens op dat elk perceel dat aanbesteed wordt als afzonderlijke 'competitie' dient te worden beschouwd en dat IJsselsteden gedurende de periode van de vermeende overtreding maar bij 3 van de in totaal 44 competities heeft ingeschreven. In het dossier ontbreekt volgens RMC ieder bewijs op grond waarvan IJsselsteden vanwege de Overeenkomst zou hebben afgezien van inschrijving, zodat merkbaarheid al onwaarschijnlijk is op basis van deze verhouding van 3/44]. Bovendien waren er bij al deze aanbestedingen twee andere inschrijvers, zodat voldoende aannemelijk is dat elk merkbaar effect ontbreekt.
144. De Raad stelt voorop dat voor de beoordeling van de merkbaarheid van de Overeenkomst de gezamenlijke positie van de betrokken ondernemingen bepalend is en niet moet worden gekeken naar het eventuele geringe aandeel van slechts één der aangesloten partijen. Waar de afspraak is gemaakt dat RMC en IJsselsteden in het algemeen niet op elkaars gebied offreren, kan overigens niet uit gevallen waarin IJsselsteden niet inschrijft worden afgeleid dat zij over een zwakke positie beschikt, hetgeen RMC in strijd met de logica doet. De gevallen waarin IJsselsteden potentieel had kunnen inschrijven maar dit in het kader van de afspraak heeft nagelaten, tellen uiteraard mee.
145. De Raad baseert zich op de informatie die in de onderzoeksfase bij diverse aanbieders en opdrachtgevers van contractueel taxivervoer is verkregen. Op grond daarvan zijn de voornaamste concurrenten en de frequentie waarmee zij inschreven in de regio Rotterdam op betrouwbare wijze in beeld gebracht.
146. Met betrekking tot de gestelde verhouding 3/44 wijst de Raad er op dat het door RMC in tabel 2 van haar schriftelijke zienswijze weergegeven schema niet overeenkomt met tabel 2

⁸¹ Besluit van de Raad van Bestuur van de NMa d.d. 9 december 2010 in de zaak 6957/Veolia-CDC-Transdev.

van de zienswijze die zij heeft overgelegd tijdens de hoorzitting.⁸² Wat daar ook van zij, uit de analyse van de Raad zoals die is weergegeven in Bijlage I, blijkt dat IJsselsteden bij een zestal aanbestedingen heeft ingeschreven in plaats van de door RMC gestelde drie gevallen.

147. RMC voert voorts aan dat blijkens het arrest van de Hoge Raad van 18 december 2009 in de zaak Prisma in het karteltoezicht een marktafbakening uit het concentratietoezicht moet worden gevolgd.⁸³ In dit geval verwijzen zij eveneens naar het fusiebesluit van de Raad in zaak 6957/ Veolia-CDC-Transdev.
148. De Raad stelt voorop dat aan het afbakenen van de markt geen zelfstandige betekenis toekomt, maar dat marktafbakening een instrument is bij de beoordeling van een fusie dan wel van een overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging in het kader van artikel 6 Mw.⁸⁴ Daarbij wijst de Raad erop dat bij een fusie sprake is van een prospectieve toets waarbij de marktafbakening dient om de mogelijke toekomstige mededingingsrechtelijke problemen in kaart te brengen. Dit in tegenstelling tot een toets op grond van artikel 6 Mw, die retrospectief van aard is. Dit onderscheid kan tot gevolg hebben dat, op basis van dezelfde algemene analyse van de marktwerking, de specifieke beoordeling tot een ander resultaat leidt. Dit blijkt ook uit artikel 12 van de bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht.⁸⁵ De Raad begrijpt het Prisma-arrest van de Hoge Raad aldus, dat het feit dat het in die zaak niet ging om concentratietoezicht maar om een mogelijke overtreding van artikel 6 Mw, *op zichzelf* nog niet meebracht dat de relevante geografische markt anders diende te worden afgebakend, zoals het gerechtshof zonder voldoende motivering had aangenomen. Daaruit volgt niet de omgekeerde verplichting om altijd dezelfde relevante geografische markt in aanmerking te nemen.
149. In de zaak Veolia was sprake van een concentratie van twee aanbieders van contractueel taxivervoer, waarvan een van de fuserende ondernemingen, Connexion, een landelijke speler was (en is). De Raad kon deze concentratie toestaan, omdat andere spelers ondanks hun geringe aantal geacht werden voldoende tegenwicht te kunnen bieden, nu het een biedmarkt betrof. Deze uitkomst in het geval van een voor iedereen kenbare concentratie betekent niet

⁸² Zo is ten aanzien van WMO AlRiBa in de schriftelijke zienswijze aangegeven dat IJsselsteden niet kon kwalificeren, terwijl in de zienswijze die is overgelegd tijdens de hoorzitting staat dat RMC en IJsselsteden beiden hebben ingeschreven. Ten aanzien van de aanbesteding Hoekse Waard wordt in de schriftelijke zienswijze aangegeven dat RMC en IJsselsteden beiden hebben ingeschreven terwijl in de zienswijze die is overgelegd tijdens de hoorzitting staat dat alleen RMC heeft ingeschreven. Wat betreft de aanbesteding Achmea wordt opgemerkt in de schriftelijke zienswijze dat alleen IJsselsteden heeft ingeschreven terwijl in de zienswijze die is overgelegd tijdens de hoorzitting staat dat geen van de betrokken ondernemingen heeft ingeschreven.

⁸³ HR 18 december 2009, *LJN* BJ9439, *Maandblad voor Vermogensrecht*, 3, 2010 (*Prisma c.s./verweerders*).

⁸⁴ Zie GvEA EG 6 juli 2000, nr. T-62/98, Jur. 2000, p. II-02707 (*Volkswagen*), r.o. 230-231 en GvEA EG 21 februari 1995, zaak T-29/92, Jur. 1995, p. II-00289, r.o. 74.

⁸⁵ Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, *Pb.* nr. C 372.

automatisch dat heimelijke mededingingsbeperkende gedragingen van twee ondernemingen niet merkbaar zouden zijn en aldus aan de toepassing van artikel 6, eerste lid, Mw kunnen ontsnappen.

150. De Raad heeft bij de (prospectieve) beoordeling van de fusie de situatie in ogenschouw genomen in heel Nederland. De reden hiervoor is dat de met de fusie beoogde onderneming, evenals Connexxion, actief zou worden in heel Nederland en derhalve een mogelijke invloed zou kunnen hebben op de concurrentieomstandigheden bij aanbestedingen in heel Nederland. De Raad zag in het voorliggende geval geen aanleiding om bij de beoordeling een onderscheid te maken tussen bepaalde aanbestedingen of regio's. Dat kan echter in andere gevallen wel noodzakelijk zijn, zoals ook uit andere concentratiezaken blijkt.
151. Zo zag de Raad in een andere concentratiezaak aanleiding om niet alleen de mogelijke effecten op de landelijke markt van aanbestedingen te beoordelen, maar daarnaast ook een specifieke aanbesteding die plaatsvond toen het onderzoek naar de gevolgen van de concentratie werd verricht. De beoogde concentratie had in die zaak met name mogelijke gevolgen voor die bepaalde aanbesteding, aangezien de gezamenlijke onderneming met het specifieke doel werd opgericht om daarop in te schrijven.⁸⁶ Naar aanleiding van de concentratiemelding van RET en Qbuzz heeft de Raad ook bij die fusie aangegeven dat uitgebreider onderzoek nodig was om vast te stellen of de concurrentie bij de lopende aanbesteding om de Concessie Bus Rotterdam e.o. werd belemmerd.⁸⁷
152. De Raad concludeert dat zijn analyse van de betrokken markt die in aanmerking dient te worden genomen zaakspecifiek moet worden ingevuld, met het oog op de specifieke kenmerken van de afspraak of fusie in kwestie.
153. Het feit dat de RMC en IJsselsteden buiten de regio Rotterdam geen (actuele) concurrenten van elkaar waren, maakt de mededingingsbeperking in de betreffende regio niet minder merkbaar. De Raad is voorts van oordeel dat de mededingingsbeperking die het doel was van de afspraak tot het verdelen van klanten en opdrachten in de regio Rotterdam niet kon worden weggenomen door concurrentiedruk die door andere, landelijke spelers werd uitgeoefend.
154. Ten slotte merkt de Raad op, dat indien zou worden uitgegaan van een *landelijke* markt, zoals de betrokken ondernemingen stellen, de regio Rotterdam in economisch opzicht op zijn

⁸⁶ Besluit van de Raad van Bestuur van de NMa d.d. 31 oktober 2011 in zaak 7273/HTM-Qbuzz-HTM Buzz, randnummer 32.

⁸⁷ NMa nieuwsbericht van 24 oktober 2011, http://www.nma.nl/documenten_en_publicaties/archiefpagina_nieuwsberichten/nieuwsberichten/2011/51_11_ret_en_qbuzz_trekken_concentratiemelding_in.aspx.

minst een belangrijk segment daarvan vormt die voor het doel van het kartelverbod als betrokken markt in aanmerking mag worden genomen.

Conclusie

155. De Raad concludeert dat de betrokken ondernemingen geen zwakke positie innamen bij aanbestedingen voor contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam en dat er diensgevolge sprake is van een merkbare beperking van de mededinging.

5.5 Bagatelbepaling

156. RMC stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een bagatelafpraak die de drempelwaarde als bedoeld in artikel 7, tweede lid, aanhef onder a, Mw niet overschrijdt. RMC heeft in dit verband gewezen op het wetsvoorstel waarmee het marktaandeelvereiste wordt verhoogd naar 10%.
157. De Raad merkt allereerst op dat de nieuwe bagatelbepaling per 3 december 2011 in werking is getreden. Hoewel dit tijdstip ruim na de beëindiging van de overeenkomst ligt, gaat de Raad voor de beoordeling van de zienswijze van RMC uit van deze recentelijk in werking getreden bepaling.⁸⁸
158. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de gezamenlijke omzet van RMC en IJsselsteden in casu nooit lager is geweest dan de genoemde omzetgrens van EUR 1.100.000, zodat niet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 7, eerste lid, Mw is voldaan.
159. Nu niet aan de voorwaarden van artikel 7, eerste lid, Mw is voldaan, dient te worden getoetst aan de voorwaarde van artikel 7, tweede lid, aanhef en sub a, Mw (nieuw). Op grond van deze bepaling mag, om in aanmerking te komen voor de uitzondering op het kartelverbod, het gezamenlijke marktaandeel van de bij de overeenkomst betrokken ondernemingen op geen van de relevante markten waarop de overeenkomst van invloed is, groter zijn dan 10%. De formulering van deze bepaling impliceert dat de inbreukmakende gedragingen op meer dan één relevante markt van invloed kunnen zijn.
160. Naar het oordeel van de Raad is aan de voorwaarde dat het marktaandeel niet hoger is dan 10% in het onderhavige geval niet voldaan. Uit het dossier blijkt dat bij de aanbestedingen waarop RMC of IJsselsteden in de relevante periode inschreven, zij doorgaans een van de 2 à 5 inschrijvende ondernemingen waren. Indien wordt uitgegaan van gelijkwaardige ondernemingen en daarmee van gelijke kansen voor de inschrijvende ondernemingen, kan

⁸⁸ Wet van 24 november 2011, houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB), *Stb.* 2011, nr 569.

dit worden vertaald naar een marktaandeel van ten minste 20% voor ieder van de betrokken ondernemingen op zichzelf gezien. Daarmee komen RMC en IJsselsteden gezamenlijk (ver) boven de grens van 10% van artikel 7, tweede lid, sub a, Mw (nieuw).

161. Voor zover het wegen van kansen op gunning nog van belang zou zijn, constateert de Raad dat RMC of IJsselsteden een groot aantal van de in het onderzoek betrokken aanbestedingen in de regio Rotterdam gegund hebben gekregen. Hieruit blijkt dat geen sprake is van een zodanig beperkte kans dat de in het vorige randnummer genoemde percentages in een ander licht komen te staan.
162. De Raad komt tot dezelfde conclusie, ongeacht of de verhoudingen binnen de regio Rotterdam over het geheel genomen worden gezien, of de verhoudingen bij iedere aanbesteding afzonderlijk.
163. RMC verwijst in dit verband wederom naar zaak 6957/ Veolia-CDC-Transdev, randnummer 116, waarin door de Raad is uitgegaan van een nationale markt voor contractueel taxivervoer.
164. De Raad wijst erop, dat in zoverre als het uitgangspunt dat iedere aanbesteding een markt op zich vormt bij toepassing van de bagatelbepaling leidend is, het niet uitmaakt waar de betreffende aanbestedingen zich afspelen. De Raad verwijst voorts naar hetgeen hij heeft overwogen bij randnummers 148 en volgende van dit besluit.
165. De Raad is derhalve van oordeel dat niet is voldaan aan de voorwaarde van artikel 7, tweede lid, aanhef onder a, Mw (nieuw).

Conclusie

166. De Raad is van oordeel dat de overeenkomst niet binnen de reikwijdte van de bagatelvoorziening van artikel 7 Mw valt.

5.6 Artikel 6, derde lid, Mw

167. Geen van de betrokken ondernemingen heeft een gemotiveerd beroep gedaan op de uitzondering als genoemd in artikel 6, derde lid, Mw en het is de Raad niet gebleken dat aan de cumulatieve voorwaarden van deze bepaling is voldaan.

5.7 Duur van de overtreding

Aanvang van de overtreding

168. De Raad heeft bij randnummer 103 vastgesteld dat RMC en IJsselsteden op 18 december 2007 wilsovereenstemming hebben bereikt over de Samenwerkingsovereenkomst. Omdat partijen nog op de dag van ondertekening de tekst van de Overeenkomst hebben gewijzigd en aangevuld, gaat de Raad (anders dan het Rapport) niet uit van een mondelinge overeenkomst die al een dag eerder tot stand zou zijn gekomen. Het verschil van één dag is voor de beoordeling van de overtreding overigens van geen belang. Derhalve stelt de Raad de aanvang van de overtreding vast op 18 december 2007.

Einde van de overtreding

169. In het Rapport wordt uitgegaan van 27 augustus 2010 als einde van de overtreding, de datum dat IJsselsteden werd overgenomen door Taxi Govers B.V. en de directie werd vervangen. Het Rapport neemt op basis van het onderzoek aan dat de nieuwe eigenaar en directie niet op de hoogte waren van de Overeenkomst, terwijl ook RMC geen toepassing van de Overeenkomst door IJsselsteden op nieuwe aanbestedingen voorzag.
170. Hoewel de activiteiten van IJsselsteden tot het faillissement van de onderdelen van de groep nog enige tijd zijn voortgezet, waardoor mogelijk sprake zou kunnen zijn van een voorgezette overtreding, gaat de Raad er, zoals gesteld bij randnummer 95, van uit dat de Overeenkomst vanaf 27 augustus 2010 *de facto* zonder betekenis is geraakt.

171. De Raad stelt daarom 27 augustus 2010 vast als einddatum van de overtreding.

Conclusie ten aanzien van de duur van de overtreding

172. Op grond van het voorgaande stelt de Raad vast dat de overtreding van RMC en IJsselsteden ten aanzien van de aanbestedingen op het gebied van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam heeft geduurd van 18 december 2007 tot 27 augustus 2010.

5.8 Eindconclusie met betrekking tot artikel 6 Mw

173. De Raad concludeert op grond van het bovenstaande dat de Samenwerkingsovereenkomst tussen RMC en IJsselsteden van 18 december 2007 in de gegeven economische en juridische context tot doel had de mededinging te beperken dan wel te vervalsen bij aanbestedingen van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam. De betrokken ondernemingen hebben zich doorgaans conform deze afspraak (trachten te) gedragen. De Overeenkomst heeft de mededinging merkbaar kunnen beïnvloeden en wordt derhalve aangemerkt als een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw, die vanaf 18 december 2007 tot en met

27 augustus 2010 heeft geduurd. Voorts concludeert de Raad dat de overtreding niet onder de bagatelbepaling van artikel 7 Mw valt en dat artikel 6, derde lid, Mw evenmin van toepassing is.

6 OVERTREDERS

Beoordelingskader

174. Op grond van artikel 56, lid 1, Mw kan de Raad, ingeval van overtreding van artikel 6 Mw de overtreder beboeten. Onder overtreder wordt op grond van artikel 5:1, eerste lid, Awb onder meer verstaan degene die de overtreding pleegt. Blijkens de Memorie van Toelichting bij de Vierde Tranche van de Awb is voor het antwoord op de vraag wie als overtreder kan worden aangemerkt met name van belang tot wie het wettelijk voorschrift zich richt. Slechts degene tot wie het wettelijk voorschrift zich richt, kan dit voorschrift overtreden.
175. Artikel 6 Mw richt zich in navolging van de communautaire mededingingsregels tot “ondernemingen”.⁸⁹ Het begrip “onderneming” omvat elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.⁹⁰ Het begrip “onderneming” valt niet noodzakelijkerwijze samen met het begrip “rechtspersoon” zoals dat in het nationale recht wordt gehanteerd; een onderneming kan ook uit een samenstel van verschillende rechtspersonen bestaan. De “onderneming” die de overtreding heeft begaan is derhalve niet noodzakelijkerwijs dezelfde entiteit als de specifieke rechtspersoon binnen een groep van ondernemingen waarvan de vertegenwoordigers daadwerkelijk aan de kartelgedragingen hebben deelgenomen. In Europese rechtspraak is in dit verband aangegeven dat de mededingingsregels zich richten tot economische eenheden die bestaan in een unitaire organisatie van personele, materiële en immateriële elementen, welke op duurzame basis een bepaald economisch doel nastreeft en kan bijdragen tot het begaan van een in die bepaling bedoelde inbreuk.⁹¹
176. Hoewel artikel 6 Mw zich tot “ondernemingen” richt en het begrip “onderneming” een economische werkingssfeer heeft, kunnen slechts rechtssubjecten (juridische entiteiten) aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op die bepaling. Wanneer het bestaan van een inbreuk op de mededingingsregels is bewezen, moet derhalve worden bepaald welke juridische entiteit(en) de onderneming exploiteerde(n) gedurende de periode waarin de inbreuk is gemaakt, teneinde deze aansprakelijk te stellen.

⁸⁹ Zie artikel 1 sub f Mw.

⁹⁰ Zaak C-41/90, *Höfner en Elser t. Macrotron*, Jurispr. 1991, blz. I-01979.

⁹¹ Zie arrest, 10 maart 1992 in zaak T-11/89, *Shell*, punt 311 en arrest 14 mei 1998 in zaak T-352/94, *Mo och Domsjö AB*, rechtsoverweging 7-96.

177. In geval van moeder-dochterverhoudingen, kan volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie het gedrag van een dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij worden toegerekend, met name wanneer de dochtermaatschappij, hoewel zij een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft, niet zelfstandig haar marktgedrag bepaalt, maar in hoofdzaak de haar door de moedermaatschappij verstrekte instructies volgt, inzonderheid gelet op de economische, organisatorische en juridische banden die hen verenigen.⁹² De reden daarvoor is dat de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij in een dergelijke situatie deel uitmaken van één economische eenheid en derhalve één enkele onderneming in de zin van het mededingingsrecht vormen.
178. Volgens vaste rechtspraak kan er in die situatie voor gekozen worden om de aansprakelijkheid voor inbreukmakend gedrag toe te schrijven aan de moedermaatschappij, de dochtermaatschappij, of aan de moedermaatschappij hoofdelijk met haar dochtermaatschappij.⁹³
179. In het bijzondere geval waarin een moedermaatschappij 100% van het kapitaal in handen heeft van haar dochtermaatschappij die een inbreuk op de mededingingsregels heeft gepleegd, kan deze moedermaatschappij beslissende invloed uitoefenen op het gedrag van deze dochter en bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat die moedermaatschappij metterdaad een beslissende invloed uitoefent op het commerciële beleid van haar dochter.⁹⁴ In die omstandigheid volstaat het dat wordt bewezen dat het gehele kapitaal van een dochtermaatschappij in handen is van haar moedermaatschappij. Vervolgens kan de moedermaatschappij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de aan de dochtermaatschappij opgelegde boete, tenzij de moedermaatschappij, die dat vermoeden moet weerleggen, afdoende bewijzen overlegt die aantonen dat haar dochtermaatschappij zich op de markt autonoom gedraagt, aldus het Hof van Justitie.⁹⁵ Hierbij wordt opgemerkt dat een moedermaatschappij alleen aansprakelijk is voor de periode dat zij beslissende invloed heeft kunnen uitoefenen.⁹⁶
180. Voorts heeft het Hof van Justitie gepreciseerd dat hoewel – naast het bezit van 100% van het kapitaal – extra omstandigheden kunnen wijzen op beslissende invloed van de moedermaatschappij, het aanvoeren van dergelijke extra omstandigheden niet noodzakelijk is om van het vermoeden van beslissende invloed uit te kunnen gaan.⁹⁷

⁹²Hof van Justitie, 10 september 2009, *Akzo N.V.*, zaak C-97/08, rechtsoverweging 58.

⁹³Gerecht, 24 maart 2011, zaak T-386/06, *Pegler*, rechtsoverweging 103 en daarin aangehaalde jurisprudentie.

⁹⁴Hof van Justitie, *Akzo N.V.*, zaak C-97/08, reeds aangehaald, rechtsoverweging 60.

⁹⁵Hof van Justitie, *Akzo N.V.*, zaak C-97/08, reeds aangehaald, rechtsoverweging 62.; CBb, *L/N*: B05193, 18 november 2010, rechtsoverweging 3.4.4.8.

⁹⁶Hof van Justitie, 16 november 2000, *KNP*, zaak C-248/98 P, *Jurispr.* 2000, blz. I-9641, rechtsoverweging 73; Hof van Justitie, 16 november 2000, *Cascades*, zaak C-279/98 P, *Jurispr.* 2000, blz. I-9693, rechtsoverwegingen 77-80, Gerecht, 30 mei 2006, *Oostenrijkse banken*, T-198/03, rechtsoverweging 332.

⁹⁷Hof van Justitie, 10 september 2009, *Akzo N.V.*, zaak C-97/08, rechtsoverweging 61, Hof van Justitie, 20 januari 2011, *Quimica*, zaak C90/09 P, rechtsoverwegingen 41 en 42.

Toepassing op de feiten en omstandigheden van deze zaak

181. De Raad stelt vast, hetgeen ook niet is bestreden, dat RMC en IJsselsteden gedurende de periode van de overtreding, beiden actief waren op het gebied van contractueel taxivervoer. Zij verrichtten daarmee economische activiteiten.
182. De Raad rekent de overtreding aan de volgende juridische entiteiten toe. Zij zijn overtreder in de zin van artikel 5:1 Awb.

RMC

183. Uit de feiten en omstandigheden zoals beschreven in hoofdstuk 4 is gebleken dat Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. via haar [leidinggevend] en werknemers rechtstreeks betrokken is geweest bij de gedragingen die de overtreding vormen. De Raad rekent de overtreding derhalve toe aan Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.

IJsselsteden

184. Uit de feiten en omstandigheden zoals beschreven in hoofdstuk 4 is gebleken dat IJsselsteden Beheers Groep B.V. en IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. via hun [leidinggevend] rechtstreeks betrokken zijn geweest bij de gedragingen die de overtreding vormen.⁹⁸ De Overeenkomst is getekend namens IJsselsteden Taxi Combinatie B.V., maar gold, volgens de verklaring van de heer [C] (IJsselsteden) ook namens IJsselsteden Beheers Groep B.V. De Raad rekent de overtreding derhalve toe aan IJsselsteden Beheers Groep B.V. en IJsselsteden Taxi Combinatie B.V.
185. IJsselsteden Beheers Groep B.V. was voorts ten tijde van de overtreding enig aandeelhouder van IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. Op grond daarvan neemt de Raad aan dat IJsselsteden Beheers Groep B.V. beslissende invloed uitoefende op het marktgedrag van IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. Aangezien IJsselsteden Beheers Groep B.V. geen zienswijze naar voren heeft gebracht om het vermoeden van beslissende invloed te weerleggen, rekent de Raad de overtreding van IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. toe aan IJsselsteden Beheers Groep B.V.

Conclusie

186. De Raad rekent de overtreding van artikel 6 Mw toe aan: Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V., IJsselsteden Beheers Groep B.V. en IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. Zij zijn overtreder in de zin van artikel 5:1 Awb.

⁹⁸ IJsselsteden Beheers Groep B.V. was ten tijde van de overtreding enig bestuurder van IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. De heren [C] en [D] waren ten tijde van de overtreding beiden [leidinggevende] van IJsselsteden Beheers Groep B.V.: in de periode tot 4 maart 2010 via Institorium Beheer B.V., respectievelijk Ypsilon Beheer B.V., vanaf die datum tot 27 augustus 2010 rechtstreeks.

7 SANCTIE

Beoordelingskader

187. Ingevolge artikel 56, eerste lid Mw kan de Raad aan degene die artikel 6 Mw overtreedt een boete opleggen. Artikel 5:46, tweede lid, Awb bepaalt dat de Raad de hoogte van de boete afstemt op de ernst van de overtreding en op de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. De Raad houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.
188. Met betrekking tot de hoogte van een boete heeft de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 5d Mw beleidsregels vastgesteld om de Raad richting te geven bij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het opleggen van boetes. Omdat de overtreding tot na 1 oktober 2009 heeft voortgeduurd, zijn de Boetebeleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009 (“Boetebeleidsregels”) van toepassing.⁹⁹
189. Op grond van de Boetebeleidsregels wordt de boete vastgesteld in verschillende stappen. Allereerst bepaalt de Raad de zogeheten ‘betrokken omzet’. Aan de hand van de betrokken omzet wordt de ‘boetegrondslag’ vastgesteld. Deze boetegrondslag wordt vermenigvuldigd met een ‘ernstfactor’. Bij het bepalen van het uiteindelijke boetebedrag wordt rekening gehouden met eventuele boeteverhogende en -verlagende omstandigheden. Ten slotte is de Raad gehouden aan het wettelijk boetemaximum.
190. De Boetebeleidsregels bepalen dat de Raad de boete vaststelt met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad kan van de Boetebeleidsregels afwijken indien onverkorte toepassing daarvan tot evidente onbillijkheid leidt.

7.1 Faillissement IJsselsteden

191. Zoals opgemerkt bij randnummers 15 en 16 van dit besluit zijn IJsselsteden Beheers Groep B.V. en IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. in staat van faillissement verklaard. Uit de faillissementsverslagen blijkt dat een eventuele boete ingevolge artikel 62 Mw slechts zal leiden tot een concurrente vordering in de faillissementen van de betrokken rechtspersonen en dat enige uitkering niet is te verwachten.¹⁰⁰

⁹⁹ Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009, Staatscourant 2009, nr. 14079.

¹⁰⁰ Zie openbaar faillissementsverslag nr. 5 van 10 januari 2012 van de curator, mr. M. Maessen, www.devoort.nl.

192. De Raad is op grond hiervan van oordeel dat voorzienbaar is dat de rechtspersonen IJsselsteden Beheers Groep B.V. en IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. geen verhaal zullen bieden. De Raad legt om die reden een symbolische boete van EUR 1000 op aan IJsselsteden Beheers Groep B.V. en IJsselsteden Taxi Combinatie B.V.
193. Het voorgaande laat onverlet dat de Raad, met het oog op het eventueel opleggen van een boete aan de feitelijk leidinggevers van IJsselsteden, in dit besluit vaststelt dat IJsselsteden Beheers Groep B.V. en IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. een overtreding hebben begaan van artikel 6 Mw.
194. In het navolgende gaat de Raad in op de boetetoemeting voor RMC.

7.2 Boetegrondslag

Beoordelingskader

195. Het startpunt bij de boetetoemeting is de bepaling van de boetegrondslag. Uit artikel 5 van de Boetebeleidsregels 2009 volgt dat de Raad de boetegrondslag in een geval als het onderhavige baseert op de betrokken omzet van de overtreder.
196. De betrokken omzet wordt in artikel 1, aanhef onder b, van Boetebeleidsregels 2009 gedefinieerd als *“de waarde van alle transacties die door de onderneming tijdens de duur van de overtreding zijn verricht op het gebied van de verkoop van goederen of levering van diensten waarop de overtreding betrekking heeft, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen”*.

Toepassing op de feiten en omstandigheden van deze zaak

197. Onder de levering van diensten wordt in het onderhavige geval door de Raad begrepen: de in de relevante periode door de betrokken ondernemingen in de regio Rotterdam uitgevoerde opdrachten die door middel van aanbestedingen zijn verkregen.
198. De betrokken omzet van RMC bestaat uit de opbrengst die zij in de periode van 18 december 2007 tot 27 augustus 2010 heeft behaald met het van uitvoeren contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam, onder aftrek van kortingen en dergelijke, alsmede van over de omzet geheven belastingen. RMC heeft inzicht verschaft in haar betrokken omzet.
199. Op basis van de door RMC verstrekte gegevens gaat de Raad uit van een betrokken omzet voor RMC van EUR 64.703.220.
200. Artikel 5 van de Boetebeleidsregels 2009 bepaalt dat wordt uitgegaan van een boetegrondslag van 10% van de "betrokken omzet". De Raad neemt evenwel in aanmerking

dat voor een deel gelijktijdig met de onderhavige overeenkomst, RMC tevens een overeenkomst had met taxibedrijf BIOS-groep, waarmee met hetzelfde doel dezelfde omzet van RMC werd beschermd. De Raad neemt gelijktijdig met het onderhavige besluit een besluit in de desbetreffende zaak met kenmerk 7131/168.

201. In het geval RMC, de BIOS-groep en IJsselsteden tezamen tot één enkele overeenkomst waren gekomen en zij gedrieën hadden deelgenomen aan één enkele inbreuk, zou de betrokken omzet van RMC ook één keer voor 10% in de boetegrondslag zijn verdisconteerd. In dat (veronderstelde) geval zou ontegenzeggelijk sprake zijn van een overeenkomst met een grotere restrictieve impact op de mededinging dan in het geval van de twee (daadwerkelijk) gesloten overeenkomsten die naast elkaar bestonden.
202. Bovendien kan niet buiten beschouwing worden gelaten dat IJsselsteden in regio Rotterdam zoveel kleiner was dan RMC (en hetzelfde geldt voor de BIOS-groep): het is onwaarschijnlijk dat zij in staat moet worden geacht voor de gehele bestaande omzet in contractueel taxivervoer van RMC een bedreiging te vormen. Haar capaciteit had zich dan in de betrokken periode moeten vervelvoudigen, hetgeen niet realistisch is.
203. Op grond hiervan ziet de Raad aanleiding voor RMC uit te gaan van een boetegrondslag van 5% van de betrokken omzet, te weten EUR 3.235.161.

Zienswijze RMC en beoordeling door de Raad

204. RMC stelt zich op het standpunt dat onder aanbestedingen als bedoeld in het Rapport niet één-op-één opdrachten kunnen worden begrepen en derhalve de hiermee behaalde omzet niet onder de betrokken omzet kan worden begrepen.
205. De Raad is met RMC groep van oordeel dat deze omzet inderdaad niet onder de betrokken omzet valt. Bij de berekening van de hierboven weergegeven betrokken omzet is de omzet behaald met één-op-één opdrachten dan ook niet betrokken.

7.3 De ernst van de overtreding

Beoordelingskader

206. De ernst van de overtreding wordt bepaald door de zwaarte van de overtreding te bezien in samenhang met de economische context waarin deze heeft plaatsgevonden. De Boetebeleidsregels 2009 onderscheiden ‘minder zware’, ‘zware’ en ‘zeer zware’ overtredingen (artikel 6 Boetebeleidsregels 2009). Naargelang de ernst van de overtreding wordt de ernstfactor vastgesteld op een waarde van ten hoogste 5.

207. Bij het bepalen van de ernst van de overtreding houdt de Raad rekening met de economische context waarin de overtreding heeft plaatsgevonden. In dit verband komt, afhankelijk van het geval, onder andere betekenis toe de aard van de betrokken producten of diensten, de omvang van de markt, de grootte van de betrokken overtreders alsmede aan het al dan niet gezamenlijke marktaandeel, de structuur van de markt en de geldende regelgeving. De Raad houdt tevens rekening met de afbreuk of potentiële afbreuk aan het normale mededingingsproces en de weerslag op de economie die de betreffende gedraging in het algemeen heeft.

Toepassing op de feiten en omstandigheden van deze zaak

208. De Raad is van oordeel dat sprake is van een horizontale afspraak die in de categorie ‘zeer zware overtredingen’ valt als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Boetebeleidsregels. Deze kwalificatie komt voort uit het feit dat RMC en IJsselsteden met het aangaan van de Overeenkomst een structureel samenwerkingsverband zijn aangegaan in het kader waarvan zij wederzijds elkaars "thuismarkten" respecteerden en aldus de onderlinge concurrentie om opdrachten voor contractueel taxivervoer uit de weg gingen. Zij hebben voorafgaande aan individuele aanbestedingen contacten onderhouden en informatie uitgewisseld om deze verdeling te effectueren. Een lichtere kwalificatie ligt niet voor de hand, ook al niet omdat de overeenkomst tot het vervalsen van meerdere aanbestedingen heeft kunnen leiden, waarmee RMC en IJsselsteden het vertrouwen dat opdrachtgevers in hen stelden hebben beschaamd. Dat de betrokken ondernemingen blijkens het dossier nogal eens onenigheid hadden over wie nu precies “recht had” op welk contract, doet daaraan niet af.

209. De Raad neemt de volgende factoren in aanmerking voor het bepalen van de ernstfactor die passend is voor deze overtreding. Allereerst zijn RMC en IJsselsteden elkaars naaste concurrenten op het gebied van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam en nemen zij in deze regio gezamenlijk een relatief sterke positie in bij aanbestedingen voor contractueel taxivervoer. Met de overeenkomst hebben RMC en IJsselsteden hun onderlinge concurrentie uitgeschakeld, zowel voor reeds bestaande "eigen" contracten als voor contracten die eerder in handen waren van derden. Bovendien hebben zij afgesproken dat zij hun diensten niet zouden mogen aanbieden aan derden, die voor de thuismarkt van één van hen een bedreiging kon vormen. Daarmee werden de toetredings- en concurrentiemogelijkheden van andere dan de betrokken ondernemingen verzwakt. De Raad overweegt voorts dat de aanbestedende diensten de rechtmatige verwachting hadden concurrerende inschrijvingen te ontvangen op opdrachten waarvoor zij aanbestedingen uitschreven. Deze verwachting is door RMC en IJsselsteden geschonden. Met hun afspraken beperkten RMC en IJsselsteden het aantal concurrerende inschrijvingen en maakten zij het voor opdrachtgevers moeilijker een reëel beeld te krijgen van het aanbod op de markt.

210. Daar staat tegenover dat de afspraken tussen RMC en IJsselsteden niet marktdekkend waren. RMC en IJsselsteden waren derhalve niet in staat om zich – buiten hun onderlinge betrekkingen – aanbestedingen toe te eigenen. Zij hebben afgesproken dat steeds slechts één van hen tweeën zou inschrijven, maar zij konden daarmee niet voorkomen dat andere spelers zouden meedingen en opdrachten zouden verwerven. Deze concurrentie van derden moesten de betrokken ondernemingen nog op eigen kracht weerstaan. De Raad neemt vervolgens ook in openschouw dat de directe aanleiding voor de Overeenkomst gelegen lijkt te zijn in het afwikkelen van kwesties uit het verleden (zie randnummers 123 en volgende). Dit vormt echter geen rechtvaardiging voor de restrictieve bepalingen in de punten 8 tot en met 11 van de Overeenkomst, die op de toekomstige betrekkingen tussen RMC en IJsselsteden zagen.
211. Het voorgaande in ogenschouw nemende en het geheel der omstandigheden afwegende, oordeelt de Raad dat een ernstfactor van 3 passend is voor de onderhavige inbreuk.
212. Gelet op het voorgaande wordt de boete voor RMC – met inachtneming van artikel 6, vierde lid van de Boetebeleidsregels 2009 – berekend door de boetegrondslag met een factor 3 te vermenigvuldigen. Het resultaat bedraagt EUR 9.705.483.

7.4 Boeteverhogende en –verlagende omstandigheden

213. Zoals in artikelen 12, 13 en 14 van de Boetebeleidsregels 2009 is vermeld, neemt de Raad bij de boetevaststelling in voorkomend geval boeteverhogende of -verlagende omstandigheden in aanmerking.

Boeteverhogende omstandigheden

214. De Raad acht geen boeteverhogende omstandigheden in de zin van artikel 13 van de Boetebeleidsregels 2009 aanwezig.

Boeteverlagende omstandigheden

Zienswijze van RMC

215. RMC stelt dat sprake is van een aantal omstandigheden die volgens haar gelden als schulditsluitingsgronden c.q. boetematigende omstandigheden. Op grond daarvan is het volgens RMC onredelijk om een boete voor de vermeende overtreding op te leggen, hooguit kan een symbolische boete worden opgelegd.
216. Zo betoogt RMC dat het bijzonder lastig is om te bepalen tot op welke hoogte overleg en samenwerking met andere marktspelers binnen de kaders van het kartelverbod blijven. Zowel voor onderaanneming als voor combinatievorming geldt dat vaak zelfs na uitgebreid

juridisch en economisch onderzoek niet met zekerheid is vast te stellen of daarbij sprake is van verboden mededingingsbeperkende gedragingen of niet. Het gaat hier om een mix van horizontale en verticale afspraken waarin partijen soms (potentiële) concurrenten zijn en soms niet. Het effect op de mededinging en de toepassing van de groepsvrijstellingen 2790/1999 en 330/2010 en art 6, derde lid, Mw kan volgens RMC vaak vooraf noch achteraf eenduidig worden vastgesteld.

217. Verder is volgens RMC relevant dat sprake is van een voortdurend veranderend juridisch kader. Zij wijst daarbij op de in 2007 nieuw ingevoerde bagatelbepaling, de nieuwe Beleidsregels Combinatieovereenkomsten 2009 en de wijzingen van de Groepsvrijstelling Verticale beperkingen en de Richtsnoeren Horizontale overeenkomsten. RMC verwijst in dit verband ook naar de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak *Solétanche bachy France S.A.*¹⁰¹

218. RMC betoogt voorts dat zij voortdurend alle mogelijke medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de NMa. Zo heeft zij steeds op eerste verzoek van de NMa documenten verstrekt, heeft zij alle vragen beantwoord, zijn haar medewerkers behulpzaam geweest tijdens het bedrijfsbezoek en hebben haar commissarissen en bestuurders zich bereidwillig opgesteld tijdens de verhoren.

Beoordeling door de Raad

219. De Raad acht het feit dat marktpartijen elkaar veelvuldig en in verschillende hoedanigheden tegenkomen geen verzachtende omstandigheid. Eerder is in die situatie extra prudentie vereist, opdat de grenzen van het mededingingsrecht in acht worden genomen. Zowel de NMa als de Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd aan de hand waarvan ondernemingen zelf kunnen vaststellen waar de grenzen liggen.¹⁰² De Raad is van oordeel dat er bij de betrokken ondernemingen geen onduidelijkheid heeft kunnen bestaan over het feit dat de bepalingen 6.2 tot en met 6.4 van de tussen hen gesloten overeenkomst een horizontaal karakter hadden en dat zij elkaar daarmee de garantie gaven dat de een de ander niet zou beconcurreren bij aanbestedingen in de regio Rotterdam, dit in het bijzonder om de relatie met hun bestaande opdrachtgevers te behouden.

220. Naar het oordeel van de Raad is de situatie in de onderhavige zaak niet te vergelijken met de situatie in de zaak *Heijmans/Solétanche*. De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak in die zaak gesteld dat de vraag of de twee betrokken bouwondernemingen potentiële concurrenten van elkaar waren, niet zonder nader onderzoek was te beantwoorden,

¹⁰¹ Rechtbank Rotterdam, 4 maart 2008, *Solétanche bachy France S.A. vs de Raad*, *L/N*: BC8958.

¹⁰² Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Mededeling van de Commissie, *Pb.* C11/1; NMa Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen, *Stcrt.* 2005, nr. 67; laatstelijk gewijzigd in: *Stcrt.* 2008, nr. 77.

aangezien niet duidelijk was of één van hen onder de gegeven specifieke omstandigheden wel zelfstandig actief kon zijn of worden op de Nederlandse markt. In de onderhavige zaak is daarentegen van meet af aan duidelijk, ook voor partijen, dat zij actuele concurrenten van elkaar zijn.

221. De verwijzing van RMC naar de Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2009 treft naar het oordeel van de Raad geen doel, nu volgens de Beleidsregels Combinatieovereenkomsten 2009 pas sprake is van een combinatieovereenkomst, indien ieder van de hierbij betrokken ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk is voor de uitvoering van de aanbesteding.¹⁰³ Dit is bij de relevante aanbestedingen in de periode 17 april 2009 tot 1 maart 2011 niet aan de orde.
222. Volledigheidshalve merkt de Raad op dat, mocht er al sprake zijn van een combinatieovereenkomst, bij randnummer 41 van de Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2009 duidelijk wordt aangegeven in welke situatie een combinatieovereenkomst onder de werking van artikel 6, eerste lid, Mw valt. In dat randnummer wordt onder meer het verdelen van markten, klanten of leveranciers, waarmee onderhavige zaak parallellen vertoont, als voorbeeld hiervan gegeven. Voorts wordt bij randnummer 44 van deze Beleidsregels als een verboden combinatieovereenkomst genoemd de situatie waarin ondernemingen afspreken voor een onbepaald aantal toekomstige opdrachten telkens bij elkaar na te gaan of zij gezamenlijk willen inschrijven. Een dergelijke afspraak maakt dan in feite deel uit van een bredere samenwerking en coördinatie van marktactiviteiten met de bedoeling prijzen af te spreken, opdrachten te verdelen, markten af te schermen of concurrenten te verdringen.
223. Ook het ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende Besluit Vrijstelling combinatieovereenkomsten heeft slechts betrekking op combinatieovereenkomsten.¹⁰⁴ Er is pas sprake van een combinatieovereenkomst indien ieder van de hierbij betrokken ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Daarbij geldt de vrijstelling niet voor combinatieovereenkomsten die andere bepalingen inhouden dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor de gezamenlijke indiening en uitvoering. Het Besluit Vrijstelling combinatieovereenkomst heeft voorts geen betrekking op een reeks van aanbestedingen, maar op een gedane of aangekondigde aanbesteding.
224. Voor zover er overigens nog sprake is van wijzigingen in de regelgeving, komt daardoor een zo vergaande beperking van de onderlinge concurrentie niet in een ander licht te staan en kan dit niet tot een andere beoordeling van de overeenkomst leiden.

¹⁰³ Beleidsregels Combinatieovereenkomsten van 11 september 2009, Stcrt.2009, nr. 14082.

¹⁰⁴ Het Besluit Vrijstelling combinatieovereenkomsten, Stb 1997, 592, is na 1 januari 2009 niet gecontinueerd.

225. De Raad is van oordeel dat geen sprake is geweest van verdergaande medewerking door RMC dan vereist. De Raad verwijst in dit verband naar de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 6 mei 2010 waarin de rechtbank overweegt dat hiervoor aan twee cumulatieve criteria moet zijn voldaan:¹⁰⁵ 1) de onderneming heeft in objectieve zin verdergaand meegewerkt dan waartoe een wettelijke verplichting bestond en 2) de verdergaande medewerking dient het voor de Raad gemakkelijker te hebben gemaakt om de inbreuk vast te stellen. Dat wil zeggen dat, indien verdergaande medewerking bestaat uit het verschaffen van informatie, deze informatie voor de Raad additionele waarde moet hebben. De Raad stelt vast dat ten aanzien van RMC aan geen van beide voorwaarden voldaan is.

226. De Raad ziet in geen van de door RMC aangehaalde argumenten aanleiding om deze als boeteverlagende omstandigheden in de zin van randnummer 14 van de Boetebeleidsregels 2009 aan te merken. Evenmin ziet de Raad aanleiding om op grond van de aangevoerde argumenten aan te nemen dat er sprake is van een verminderde mate van verwijtbaarheid welke hij op enige wijze nog zou moeten verdisconteren in de hoogte van de boete. Een symbolische boete is naar het oordeel van de Raad evenmin aan de orde.

7.5 Wettelijk maximum

227. Ingevolge artikel 57, eerste lid, Mw bedraagt de boete voor een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw ten hoogste EUR 450.000 of, indien dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking. RMC heeft inzicht verschaft in de relevante omzet. Deze bedraagt voor RMC EUR 45.642.408.

228. Gelet op de door RMC overgelegde omzetgegevens stelt de Raad vast dat dit maximum in het geval van de bij randnummer 212 berekende boete voor RMC wordt overschreden. De Raad ziet derhalve aanleiding de boete voor RMC vast te stellen op EUR 4.564.240.

7.6 Conclusie sanctie

229. De boete voor RMC wordt, conform artikel 19 van de Boetebeleidsregels 2009 afgerond op een veelvoud van EUR 1.000, vastgesteld op EUR 4.564.000.

¹⁰⁵ Rb. Rotterdam 6 mei 2010, *LJN*: BM5246 (*Rendon Eindhoven B.V. vs NMa*). Het CBb heeft voorts overwogen dat deze mogelijkheid tot boeteverlaging en de daarvoor geldende voorwaarden niet als onredelijk kunnen worden aangemerkt, CBb 25 maart 2011, *LJN*: BQ5977.

8 BESLUIT

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

- I. legt aan Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, een boete op van EUR 4.564.000,-;
- II. legt aan IJsselsteden Taxi Combinatie B.V. en IJsselsteden Beheers Groep B.V. beide statutair gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, een boete op van EUR 1000,- en stelt beide rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.

Dit besluit richt zich tot ieder van de onder I en II genoemde rechtspersonen afzonderlijk.

Datum: 20 november 2012

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze,

Wg.

Henk Don

Lid van de Raad van Bestuur

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.